2024년 특허·상표
판례연구논문 공모전
우수논문집

Intellectual Property
Trial and Appeal Board

02

우수상

조춘련

통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는 특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부쟁조항의 유효 여부

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결
제 목	통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는 특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부쟁조항의 유효 여부
요 약	본 논문은 특허에 관한 부쟁조항이 유효인지 여부를 판단하는 법리를 제공하는 것을 목적으로 한다. 연구의 결과로, 본 논문은 다음과 같은 기준을 도출하였다. 첫째, 부쟁조항의 효력은 사안별로 판단되어야 한다. 부쟁조항에 대해 부정적인 태도를 보이는 유럽에서도 부쟁조항이 일률적으로 무효라고 보지는 않는다. 공정거래위원회의 지침도 예전에는 무조건 무효라고 보았으나, 2010년부터는 사안별로 판단하게 한다. 둘째, 시장지배력과 독점권이 강한 특허에 대한 부쟁조항은 무효일 가능성이 매우 높다고 보아야 한다. 그래서, 표준필수특허에 대한 부쟁조항은 특별한 경우가 아니라면 무효로 판단될 것이다. 반대로 특허가 독점권이 약한 경우, 실시료가 무료인 경우, 특허발명이 오래된 것인 경우 등에서는 유효로 판단될 가능성이 매우 높게 된다. 셋째, 소송상화해를 통한 화해합의 등 소송, 분쟁을 해결하기 위한 합의에서의 부쟁조항은 특별한 경우가 아니라면 유효라고 보아야 한다. 당사자의 자발적 분쟁해결을 권장하는 원칙에 상응하는 법리라고 생각된다. 넷째, 실질적인 분쟁이 발생하기 전에 체결된 실시계약에서의 부쟁조항은 무효로 판단될 가능성이 높다. 그러나, 그러한 실시계약에서도 해당 부쟁조항이 특허권자에 의해 강요된 것이 아닌 실시권자에 의해 자발적, 능동적으로 추가된 것이라면, 그 부쟁조항은 유효로 판단되어야 할 것이다. 한편, 실시권자와 특허권자는 부쟁조항의 도입에 다른 입장을 가질 것이다. 특허권자의 입장에서는 원칙적 무효인 상황을 제외하고는 어떤 상황에서든 부쟁조항을 두기 위해 노력해야 하고 더 나아가 부쟁조항을 위반하는 경우의 벌칙조항까지 두기 위해 노력해야 한다. 실시권자의 입장에서는 부쟁조항의 도입을 거부할 수 없다면 협상이력에서 해당 부쟁조항을 수용한 것이 능동적이 아니라 수동적이었음을 보여주는 증거를 많이 만들어야 할 것이다.
필 요 성	실시권자(licensee)가 특허무효심판을 청구할 수 있는 '이해관계인'인지 여부에 대해 대법원이 상반된 판결을 선고한 바 있다. 2019년 대법원 2017후2819 전원합의체 판결이 '통상'실시권자의 청구인 적격을 인정하여 해당 법리는 어느 정도 정리되었다. 이에 따라 특허권자가 실시권자와 실시계약을

	체결함에 있어서 특허무효심판의 청구를 금지하는 소위 '부쟁조항'(non-assertion/no-contest/no-challenge clause/provision)을 추가할 것이 예상된다. 그러한 부쟁조항의 효력이 어떠한지, 효력을 어떻게 판단하는지에 관해서 논쟁이 발생할 여지가 있으므로 연구의 필요성이 높다.
독 창 성	대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 부쟁조항의 유효 여부에 대해 직접 심리하지는 않았지만, 부쟁조항이 유효할 수 있다는 가능성을 제시하였다. 그 외에 지금까지 부쟁조항의 효력에 대해서 다룬 판례는 특허분야에서 부쟁합의와 부제소합의가 동시에 존재하는 합의에서 그 두 합의가 유효함을 전제로 심리·판단이 이루어진 2009년 특허법원 2009허1996, 2009허1989, 2009허2005 판결 등이 검색되었고, 상표분야에서 계약기간 종료 후에도 부쟁의무를 부여한 조항을 무효로 본 1987년 대법원 86후78, 79, 80 판결이 검색되었다. 그러나, 그것만으로는 특허분야에서의 여러 종류의 부쟁조항의 유효 여부를 판단하기 어렵다. 그래서, 한국에서의 일반 현황을 먼저 살펴본 후, 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 관련 법리를 비교법적으로 연구하였다. 본 논문은 부쟁조항의 유효 여부를 본격적으로 논한 최초의 논문이며, 한국 외 7개 국가의 법리를 비교법적으로 분석한 후, 그 법리를 종합한 새로운 판단기준을 최초로 제시하였다.
파급효과	대법원 2017후2819 전원합의체 판결로 인하여 앞으로는 실시계약에서 부쟁조항이 허다하게 포함될 것이 예상된다. 그러한 조항에도 불구하고 특허무효심판이 청구된 경우, 본 논문이 특허심판원이 해당 부쟁조항이 유효한 것인지 여부를 용이하게 판단할 수 있는 기준을 제시한다.

우수상

통상실시권자의 특허무효심판 청구인 적격을 인정한 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 대응하는 특허무효심판 청구를 금지하는 소위 부쟁조항의 유효 여부

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결

목 차 / Contents

1. 서 론 ····· 81
2. 특허무효심판에서의 이해관계인 법리와 부쟁조항 ····· 82
가. 무효심판 청구인으로서의 이해관계인
나. 실시권자의 청구인 적격
다. 쟁점 특정: 부쟁조항 유효 여부 및 유효하게 하는 조건
라. 연구의 범위
3. 부쟁조항의 효력에 관한 비교법적 연구 ····· 86
가. 한국의 관련 법리
나. 미국의 관련 법리
다. 유럽의 관련 법리
라. 독일의 관련 법리
마. 중국의 관련 법리
바. 일본의 관련 법리
사. 대만지구의 관련 법리
4. 특허무효 관련 부쟁조항과 관련된 필자의 제안 ····· 115
가. 주요국 법리의 정리
나. 부쟁조항 유효 여부를 판단하는 법리의 제안
다. 특허권자 입장에서의 실시계약 작성 전략
라. 실시권자 입장에서의 실시계약 작성 전략
5. 결 론 ····· 125

1 서 론

실시권자는 특허권자와 실시계약(license agreement)을 체결하여 설정된 실시 범위 내에서 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있다.[1] 실시권자는 그 실시계약의 범위 내에서는 특허권자로부터 특허권 침해소송을 제기당할 염려가 없다.[2] 반면에 실시권자는 해당 특허에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있을까? 예전에 미국 법원은 실시권자 금반언(licensee estoppel) 원칙을 적용하여 실시권자의 청구인 적격을 부정하였으나, 1969년 *Lear* 판결에서 연방대법원이 그 금반언 원칙을 폐기하였다.[3] 그래서 미국에서는 원칙적으로 실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있게 된 것이다.[4] 한국에서는 실시권자의 무효심판 청구인 적격을 부정한 대법원 판결들[5][6] 및 인정한 대법원 판결들이[7][8] 존재하였으나, 2019년 선고된 대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 따라 통상실시권자의 무효심판 청구인 적격이 인정되는 것으로 법리가 정리되었다.[9] 그러한 (통상실시권자가 특허무효심판의 청구인 적격을 가진다는) 법리로 인하여 특허권자는 실시계약을 체결함에 있어서 특허무효심판의 청구를 금지하는 소위 부쟁조항(non-assertion/no-contest/no-challenge clause/provision)을 추가할 필요성이 생겼고, 현실적으로 부쟁조항이 많이 추가될 것이 예상된다. 특허권자로서는 (실시권자가 거부하기 어색한) 부

1) 특허법 제100조, 제102조.

2) 이혜진, "실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 – 이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로", 사법 통권 제49호, 사법발전재단, 2019, 616면.

3) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 669 (1969).

4) Scott G. Greene, *The Return of the King: Rethinking Lear, MedImmune, and the Effects of Licensee Estoppel in the Context of AIA Post-Grant Procedures*, 71 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 81, 102 (2015).

5) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결.

6) 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결.

7) 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결.

8) 대법원 1980. 3. 25. 선고 79후78 판결.

9) 대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 '통상'실시권자에게만 적용되는 것이며, '전용'실시권자에게는 무효심판 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다고 주장한 논문: 이서영·정차호, "전용실시권자(exclusive licensee)의 특허무효심판 청구인 적격", 법학연구 제35권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2024.

쟁조항을 추가하여 손해를 볼 것이 없기 때문이다.[10] 실시계약을 체결하는 장면에서뿐만 아니라 특허권 침해분쟁이 발생한 후 특허권자와 침해혐의자가 협상에 따라 화해계약을 체결하는 와중에도 부쟁조항을 포함시킬 수 있을 것이다. 대법원 2017후2819 전원합의체 판결은 부쟁조항의 효력에 대하여 직접적으로 언급하지 않았고,[11] 특허분야에서 부쟁조항이 유효인지 여부에 대하여 특허법원이 선고한 2009허1996, 2009허1989, 2009허2005 판결 등이 발견되었지만 해당 재판부는 부쟁조항의 효력에 대해 본격적으로 분석하지 않았고 오직 유효함을 전제로 심리했음을 확인할 수 있을 뿐이다. 이 글은 부쟁조항이 어떠한 경우에 유효 또는 무효인지를 판단하는 기준을 제시하는 것을 목적으로 한다. 그 목적을 달성하기 위해 먼저 실시권자의 무효심판 청구인 적격 및 부쟁조항과 관련된 판결과 규정들을 살펴보고, 그다음으로 부쟁조항의 효력에 관한 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 법리들을 비교, 분석한 후 가장 바람직한 판단기준을 제안하고자 한다.

2 특허무효심판에서의 이해관계인 법리와 부쟁조항

가 무효심판 청구인으로서의 이해관계인

특허법 제133조 제1항은 심사관 외에 '이해관계인'만이 특허무효심판을 청구할 수 있다고 규정한다. 대법원 판결에 따르면 이해관계인은 "당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람"을 말하고, 그중 당해 특허발명과 동일한 종류의 물품을 제조·판매 하였거나, 하고 있거나, 할 자도 포함된다고 한다.[12] 이와 같이 청구인을 이해관계인으로(심사관은 별도 논의) 제한하는 것은

10) 본 연구를 통해 살펴본 많은 사례에서 부쟁조항이 무효라거나 집행불능이라고 판단한 사례는 많았으나, 해당 조항으로 인해 특허권자에게 벌칙을 부여한 사례는 전혀 없었다.

11) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

12) 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결, 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결 등.

무효심판의 준사법적 성격을 고려해서 민사소송법에서의 '이익 없으면 소권 없다'는 원칙을 따르는 것이다.[13] 또, 무효심판 청구권을 특허권자로부터 권리의 대항을 받았거나 받을 염려가 있는 자에게만 부여하여 특허권자를 상대로 청구되는 무효심판의 수를 제한하여 권리의 법적 안정성을 도모하는 동시에 특허심판원 나아가 특허법원, 대법원의 자원낭비도 방지하는 것이 그 규정의 취지이다.[14]

다만, 청구인 적격을 이해관계인으로 제한해야 하는지 여부에 관하여 ① 주요국은 특허무효심판 청구인을 제한하지 않는 점, 청구인을 이해관계인으로 제한함으로써 마땅히 무효되어야 하는 특허가 쉽게 무효될 수 없으므로 특허권자가 타인의 실시를 방해하고 공중에 피해를 끼침은 물론 산업발전에 지장을 초래한다는 점에 비추어 보면 무효심판의 청구인을 '이해관계인'에서 '누구든지'로 확대할 필요가 있다는 견해와[15] ② 현실적으로 이해관계가 없는 자가 무효심판을 청구하는 사례는 매우 드물고, 이해관계인인지 여부를 조사하는 데 심판이 지연되므로 이해관계인 규정을 삭제하는 것이 바람직하다는 견해가[16] 있다.

나 실시권자의 청구인 적격

실시권자는 특허실시계약의 기간 내에 특허권자로부터 특허권 침해소송을 제기당할 염려가 없으므로 이해관계인이 아닌 한 측면과 특허가 무효되면 실시료를 더 이상 지불하지 않아도 되므로 이해관계인이라는 다른 측면을 동시에 가진다.[17] 통상실시권자가 무효심판을 청구할 이해관계가 있는지 여부에 관하여 종래 대법원 판결은 "특허무효심판 청구인이 통상실시권을 허여 받았다는 사실만으로 당사자

13) 박영규, "무효심판의 당사자로서 실시권자", 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014, 513면.

14) 김동준, "실시권자의 특허무효심판청구에 관한 소고", 충남대학교 법학연구 제18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007, 118면.

15) 정차호·양성미, "특허무효심판 청구인 적격 - '이해관계인'에서 '누구든지'로 확대 방안 -", 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014, 532-533면.

16) 김현호, "특허심판의 당사자", 발명특허 제35권 제1호, 한국발명진흥회, 2010, 71면.

17) 김수철, "실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰", 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010, 8면.

간에 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으므로 이해관계인에 해당한다"고 판시한 경우와[18][19] "실시권자는 법률상 아무런 장애 없이 특허발명을 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한 이해관계인에 해당하지 않는다"고 판시한 경우로[20][21] 나누어졌다. 특히 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결은 제품순판매액의 3%를 실시료로 지급해야 하는 사안인데, 대법원은 통상실시권자의 무효심판 청구의 이해관계를 인정하였다.[22]

그 후의 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결에서 대법원은 "특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없고, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없으며, 실시권자는 무효심판을 통해 특허를 무효시켜 무효심결을 받음으로써 실시료 지급이나 실시 범위 등 제약에서 벗어날 수 있으므로" 통상실시권자의 이해관계를 인정하여야 한다고 설시하여 통상실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는지 여부에 관한 문제는 정리가 된 것으로 보인다. 그 대법원 전원합의체 판결은 통상실시권자인지 전용실시권자인지를 특정하지 않았다. 따라서 전용실시권자가 무효심판을 청구할 이해관계가 있는지 여부에 대하여 ① 전용실시권자는 특허권자와 대등한 지위에 있고 특허권자의 무효심판 청구인 적격을 인정하지 않는다면 전용실시권자도 청구인 적격을 인정하지 않아야 한다는 견해,[23] ② 전원합의체 판결이 전용실시권자에게도 적용될지는 불명확하므로 추가적인 연구를 통해 이론적 근거가 명확히 밝혀진 다음 판단하여야 한다는 견해[24], ③ 전용실시권자도 실시범위 내에서 실시권을 행사해야 하므로 전용

18) 대법원 1980. 7. 22. 선고 79후75 판결.
19) 대법원 1980. 3. 25. 선고 79후78 판결.
20) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결.
21) 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결.
22) 대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결.
23) 이서영·정차호, 앞의 논문, 357면.
24) 이종우, "전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 선고 2019. 2. 21. 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 - ", 2019년 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020, 173면.

실시권자의 이해관계 판단에 있어서 통상실시권자와 다르게 판단할 필요가 없다는 견해[25][26] 등이 있다. 필자는 ①의 견해가 타당하다고 생각한다.

대법원이 2017후2819 전원합의체 판결에서 "실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다"고 표현한 점에 주목할 필요가 있다. 이는 대법원이 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸되지 않았다고 판단한 근거 중의 하나였다. 달리 말하면 만약 실시권자가 실시계약 중에 특허무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다면 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸될 수 있음을 인정한 것이다. 즉, 대법원은 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되었다면 그 조항의 효력으로 인하여 이해관계가 인정되지 않을 가능성을 제시한 것이다.

다 쟁점 특정: 부쟁조항 유효 여부 및 유효하게 하는 조건

대법원 2017후2819 전원합의체 판결에 의해 통상실시권자가 (특별한 경우를 제외하고는) 특허무효심판을 청구할 이해관계를 가진다는 점은 명확해졌다. 실시권자는 특허권자를 제외하고는 해당 특허발명에 대하여 가장 잘 아는 자이고 무효사유를 쉽게 발견할 수 있는 위치에 있으며, 실시료의 지급 등 제약에서 벗어나고 싶은 심정을 가진 자로서 해당 특허를 무효시킬 수 있는 가장 유력한 자라고 할 수 있다.[27] 이에 특허권자는 특허권의 안정성을 확보하기 위해 실시계약 중에 자신의 특허권에 대하여 다투는 것을 금지하는 부쟁조항을 요구하는 방법으로 실시권자에게 부쟁의무를 부과할 가능성이 높다. 그리고 그 장면에서 (곧) 실시권자가 그 조항을 거부하기도 어색하다. 그렇게 실시계약에 부쟁조항이 포함된 경우, 그 부쟁조항이 유효한지 여부가 중요한 쟁점이 된다. 특허실시계약에서 부쟁조항을 허용할 것인지에 대해 설시한 판례는 검색되지 않았지만, 부쟁의무를 부과하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 넘은 행위로서 부당한 권리행사로 판단될 여지

25) 이혜진, 앞의 논문, 607면.

26) 김수철, 앞의 논문, 10면.

27) 박준석, "라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -", 산업재산권 제54호, 한국지식재산학회, 2017, 152면.

가 있다. 대법원 2017후2819 전원합의체 판결로 인하여 향후에는 특허실시계약에서 부쟁조항이 많이 활용될 것이 예상되므로, 해당 부쟁조항이 유효한지 여부와 어떤 조건에 부합하면 유효인지에 대한 검토가 필요하다.[28]

라 연구의 범위(실시계약에서의 부쟁조항을 중심으로 하되, 화해계약 등도 포함)

부쟁조항이 생성되는 여러 장면이 예상된다. 실시계약을 체결할 때 실시권자에게 특허의 유효성을 다투지 못하도록 약정하는 부쟁조항을 직접 도입하는 경우가 있고, 그 밖에 특허권 침해로 인한 분쟁이 발생한 후 화해합의(settlement agreement)를 통해 부쟁조항을 약정하는 경우도 있다. 다양한 경우에 체결된 부쟁조항의 효력이 사안에 따라 다를 수 있다. 본 연구는 실시계약 중의 부쟁조항을 위주로 검토하면서 화해합의 등을 통해 형성된 부쟁조항의 효력에 대해서도 살펴보고자 한다. 그러한 목적을 달성하기 위해서 한국 외에 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본, 대만지구의 관련 법리를 비교법적으로 분석할 것이다.

3 부쟁조항의 효력에 관한 비교법적 연구

가 한국의 관련 법리

(1) 실시계약 중의 부쟁조항

실시계약 중의 부쟁조항이란 실시권자에게 특허의 유효 여부를 다투는 것을 금지하는 것을 약정하는 조항이고, 그 조항이 유효하면 실시권자는 특허무효심판을 청구할 수 없다.[29] 그 유효한 조항에두 불구하고 실시권자가 특허무효심판을 청구하는 경우 심판원은 그 청구를 각하해야 한다. 부쟁조항을 허용하는 법리는 특허권

28) 최치호, “특허실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제1호, 한국지식재산연구원, 2008, 2면.

29) 최치호, 위의 논문, 3면.

자가 실시계약을 더 자유롭게 체결하는 환경을 제공하여 경쟁을 촉진할 수 있고, 특허권자의 지위를 강화하여 기술개발의 의욕을 고취하고, 기술이전을 촉진하여 산업발전에 기여할 수 있다.[30] 계약자유의 원칙에 의하면 부쟁조항은 기본적으로 유효하여야 하지만, 독점금지법을 위반한다고 판단되는 경우 또는 특허정책에 반한다고 판단되는 경우에는 유효성이 부정될 수도 있다.[31]

한국의 경우 특허분야에서 부쟁조항의 효력에 대하여 직접적으로 판단한 판례는 발견되지 않았다.[32][33] 그러나, 2017후2819 전원합의체 판결에서 대법원은 앞서 본 바와 같이 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되었다면 그 조항의 효력으로 인하여 이해관계가 소멸될 가능성이 있음을 제시한 바가 있었고, 그밖에 2009. 12. 23. 선고된 특허법원 2009허1989 판결에서[34] 부쟁합의과 관련된 내용이 언급되어 있음이 발견되었다. 그 판결 내용은 다음과 같다.

> 을 제1호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 피고는 2004. 10. 20. 피고가 원고에게 이 사건 특허발명의 실시권을 허여하면서 원 피고 사이에 <u>이 사건 특허발명과 관련하여 일체의 민·형사상 소송 또는 이의를 제기하지 아니하기로 약정한 사실</u>이 인정되고, 또한 원고가 2008. 11. 초경 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구한 사실, 이에 대하여 피고는 2008. 11. 말경 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 기한 침해금지 가처분 신청사건을 제기하였고, 그 신청서 부본이 2008. 12. 2. 원고에게 송달된 사실 등은 모두 당사자 사이에 다툼이 없는바, 위 인정사실에 의하면 이와 같이 원고의 부제소 특약 위반행위(등록무효심판청구)가 먼저 이루어진 다음에 이에 대항하여 피고의 침해금지 가처분 신청사건이 제기된 것이어서, 이러한 <u>피고의 가처분 신청사건</u>

30) 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙((EC)No 772/2004)을 중심으로 -”, 경영법률 제20권 제2호, 한국경영법률학회, 2010, 103면.

31) 최치호, 앞의 논문, 11면.

32) 박준석, 앞의 논문, 153면.

33) 일반적인 온라인 검색 외에 대법원 도서관(일산)의 검색컴퓨터를 통해 직접 검색하였으나, 관련 판결의 발견에 실패하였다.

34) 같은 사건에서 특허법원 2009. 11. 6. 선고 2009허1996 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1989 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결이 있다. 여기서 2009허1989 판결을 대표로 소개하고자 한다.

> 제기는 원고의 부제소 특약 위반행위를 **해지사유**로 삼아 위 합의계약을 해지한다는 의사표시가 포함되었다고 할 것이므로, 그러한 의사표시가 담긴 신청서 부본이 원고에게 송달됨으로써 위 부제소 특약이 포함된 합의계약은 그 무렵 적법하게 해지되었다고 할 것이다.

이 사건에서의 부쟁조항과 부제소합의는 원고와 피고가 해당 특허발명에 대하여 분쟁이 일어난 후 2004. 10.경 합의에 따라 실시권을 허여하면서 이루어진 것이다.[35] 그 후 2008. 11.초 무효심판이 청구되었고, 2008. 11.말 침해소송 가처분 신청사건이 제기되었다. 이에 특허법원은 원고의 무효심판 청구 행위가 부쟁조항과 부제소합의의 해지사유로 볼 수 있고, 피고의 침해소송 가처분 신청은 합의계약을 해지하자는 의사표시가 포함된다고 판단하였다. 달리 말하면, 특허법원은 그러한 부쟁조항과 부제소합의가 유효하다는 전제 하에서 해당 계약의 해지 여부를 주어진 사실관계에 따라 판단한 것이다.

한편, 상표분야에서 부쟁조항의 효력에 대하여 판단한 사건도 발견되었다. 등록상표의 부정사용취소에 관한 사건에서 상표사용계약을 체결할 때 그 사용계약이 해지된 후에 해당 상표권을 다투지 않기로 하는 취지의 약정에 대하여 대법원은 "이와 같은 이해관계의 사전포기 합의를 허용하게 되면 상표권자의 상표부정사용을 방지하기 위한 제재적 규정인 동시에 일반수요자의 이익을 도모하기 위한 공익적 규정인 상표법 제45조 제1항 제1호의 적용을 당사자들의 합의에 의하여 임의로 배제할 수 있는 결과가 될 뿐만 아니라 상표권자의 위법행위를 조장할 우려마저 없지 않으므로 이와 같은 이해관계의 사전포기약정은 위 규정취지에 비추어 그 효력이 없다고 봄이 상당하다"고 판시한 바 있다.[36]

부쟁조항과 관련하여 공정거래위원회의 1997년 「국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준」 제3조가 제3자 또는 실시권자가 계약기술의 유효성을 다투는

35) "원고는 2004. 10.경 피고와 사이에 당시 분쟁 중이던 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판 및 침해금지 가처분 신청사건 등에 대하여 상호 원만히 합의하면서, 향후 이 사건 특허발명과 관련한 일체의 심판청구 내지 소제기를 하지 않는다는 내용의 부제소 특약을 하였으므로 …".

36) 대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78, 79, 80 판결.

경우 특허권자가 계약을 해지할 수 있다는 부쟁의무의 부과는 불공정거래행위에 해당한다고 규정하였었다.[37] 하지만 그 규정은 2009년에 삭제되었고 2010년 개정된 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」으로 통합되었다.[38] 개정된 그 심사지침에서 "무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위"는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있다고 새롭게 규정하였고,[39] 그 부당성에 있어서 "해당 특허발명과 부과된 조건의 관련성 즉 부과된 조건이 해당 특허발명의 실시를 위해 필수적인지 여부, 해당 조건이 관련 기술의 이용을 촉진하는데 기여하는지 여부, 해당 조건에 대한 특허권의 소진 여부 등"을 판단기준으로서 중요하게 고려하여야 한다고 제시하였다.[40] 해당 심사지침은 「지적재산권의 행사에 대한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 적용의 일반 원칙과 구체적 심사기준을 제시하기 위한 것이고,[41] 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이므로 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 적용된다.[42] 따라서 특허권자가 실시권자로 하여금 특허의 유효 여부를 다투지 못하게 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로서 무효로 판단될 '가능성'이 있다.[43] 본 논문은 실제로 어떤 경우에 무효라고 판단되어야 하는지에 대한 기준을 제시하고자 한다.

(2) 재판상 화해에 따라 이루어진 부쟁조항

재판상 화해를 통하여 체결한 합의 중의 부쟁조항의 경우는 일반 부쟁조항과 달리 취급하여야 할 것이다. 재판상 화해는 소송이 제기되기 전에 법원에 신청하는

37) 국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준 제3조 15.

38) 김수철, 앞의 논문, 16면 각주 54.

39) 다만, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.

40) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 III. 3. 라. 참조.

41) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 I. 1. 참조.

42) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II. 2. 나. 참조.

43) 이수미·신규환, "특허 실시권자의 무효심판 청구 권리와 부제소 특약의 효력에 관한 연구", 산업재산권 제64호, 한국지식재산학회, 2020, 253면.

'제소전화해'와[44] 소송 진행 중에 이루어지는 '소송상화해'로 나누어지고, 그러한 화해로 이루어진 조서는 확정판결과 같은 효력을 갖는다.[45] 즉, 확정판결이 가지는 기판력이 그 화해조서에도 그대로 적용되는 것이다. 따라서 화해조서에 무효심판을 제기하지 않겠다는 부쟁조항이 기재되어 있는 경우 그 조항은 당사자에게 기판력을 발생시키고 그 당사자가 무효심판을 제기할 수 없게 된다.[46]

이와 관련하여 대법원은 권리자와 침해자 사이에 침해를 전제로 체결한 무효심판청구를 취하하기로 하는 합의가 유효한 것으로 보았고, 그 합의로 인해 침해자는 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸되었다고 판단한 바 있다.[47] 그러한 합의의 효력은 실시권자와 실시권자로부터 실시권을 양도받은 자 또는 재실시권을 설정받은 자에게도 미친다.[48]

나 미국의 관련 법리

(1) 유형

부쟁조항은 그 내용에 따라 ① 실시계약에 직접 특허의 유효에 대하여 다투는 행위를 금지하는 조항과 ② 특허의 유효를 다투는 행위에 벌칙을 부여하는 조항으로 나눌 수 있다.[49] 두 번째 유형에서는 경제적 불이익을 부여할 수 있고 계약의 특권을 잃게 할 수도 있다.[50] 경제적 불이익으로서 고액의 위약금을 약정하거나, 특허의 유효를 다투는 경우 실시료를 (심지어 소급하여) 올릴 수 있다.[51] 또한 계약의 특권과 관련하여 특허의 유효를 다투는 순간 실시계약은 자동 종료되거나 특허권자가 실시계약의 종료 여부를 결정하게 되고, 실시계약이 종료된 후부터는 실

44) 민사소송법 제385조 제1항.
45) 민사소송법 제220조.
46) 대법원 2002. 12. 6. 선고 2002다44014 판결.
47) 특허법원 2000. 7. 14. 선고 2000허1115 판결.
48) 대법원 1976. 6. 8. 선고, 72다1842 판결.
49) Thomas K. Cheng, *Antitrust Treatment of the No Challenge Clause*, 5 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 437, 441 (2016).
50) *Id,* at 441-42.
51) *Id,* at 442.

시권자의 실시는 침해가 되고 결과적으로 특허가 유효한 것으로 판단되면 특허권자는 그 실시권자를 상대로 침해소송을 제기할 수 있다. 그래서 그러한 실시계약 종료조항은 실시권자를 위협하는 효과를 가지므로 실시권자가 특허를 무효시킬 가능성을 높게 보는 경우에만 무효심판을 청구할 것이고 대부분의 무효심판 청구를 막을 수 있다.[52] 또한 벌칙조항이 아닌 장려조항의 모습을 가질 수도 있다. 예컨대 실시계약 종결까지 무효심판을 청구하지 않으면 실시료의 일부를 반환하는 조항을 말한다.[53][54]

부쟁조항이 포함되는 계약의 체결시기에 따라 ① 어떠한 소송도 존재하지 않는 상황에서 체결하는 단순 실시계약, ② 소송이 긴박한 상황 또는 개시된 후 체결하는 화해합의, ③ 양 당사자가 법원 앞에서 하는 소송상화해에 따라 작성된 화해조서로 구별된다.[55]

(2) 미국 법원의 시기별 태도변화

(가) *Lear* 판결(1969) 전의 시기 = 부쟁조항 불필요

Lear v. Adkins 판결 이전, 미국 대법원은 *Kinsman v. Parkhurst* 판결에서[56] 실시권자 금반언(licensee estoppel)의 원칙을 지지하였다. 즉, 실시권자가 실시계약을 체결하였다면 해당 계약이 대상으로 하는 특허의 유효를 인정하는 것으로 간주하여 그 실시권자가 특허의 유효를 다투는 행위는 허용되지 않는 것이다. 그러한 법리에서는 부쟁조항을 따로 둘 필요가 없었다.

(나) *Lear* 판결(1969)부터 CAFC 설립(1982) 전의 시기 = 부쟁조항은 일반적으로 무효

Lear v. Adkins 판결에서 미국 연방대법원은 실시권자 금반언 원칙은 응당 무

52) *Id,* at 442-43.

53) Alan D. Miller & Michal S. Gal, *Licensee Patent Challenges*, 32 Yale J. on Reg. 121, 131 (2015) .

54) 예를 들면 실시료를 협상할 때 실시료율을 3%로 설정하였다가, 실시권자가 무효심판을 청구하지 않는 경우 1%를 반환하는 조항을 말한다.

55) Thomas K. Cheng, supra, at 445.

56) Kinsman v. Parkhurst, 59 U.S. 289 (1855).

효로 되어야 하는 특허를 유지함으로 인해 발생하는 사회 폐해를 외면한다고 지적하였고,[57] 무효되어야 마땅한 특허(소위 '나쁜 특허')를 무효시켜야 하는 공공정책(public policy)은 특허권자의 이익보다 우선이라고 설시하였다.[58] *Lear* 판결이 부쟁조항에 대하여 직접 언급하지는 않았으나, 그 후 많은 사건에서 하급심 법원은 나쁜 특허(bad patent)를 무효시키는 것이 공공이익에 유리하다는 점을 근거로 부쟁조항은 무효라고 판단하였다.[59] 그 당시 특허권을 (나쁜) 독점권(monopoly)으로 보는 사회적 분위기에 따른 판단이라고 생각된다.[60]

1970년의 *Bendix v. Balax* 사건에서 실시계약의 종료 후에도 해당 특허의 유효를 다투는 것을 금지하는 부쟁조항의 유효 여부가 다투어졌다.[61] 특허권자는 피고를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였고 피고는 해당 특허가 무효라고 주장하면서 특허권자가 부쟁조항을 체결함으로써 특허권을 남용하여 독점금지법을 위반하였다고 주장하였다.[62] 그 사건에서 법원은 실시권자가 특허무효를 다투는 것을 금지하는 권리는 특허권자의 독점적 권리에 해당하지 않고, 부쟁조항은 불필요한 독점적인 위험을 초래할 것이며, 실시계약의 기간이 지나고도 특허의 유효에 대한 분쟁이 발생하므로 그러한 위험은 실시권자 금반언의 원칙이 초래하는 위험보다 더욱 크다고 보고 해당 부쟁조항의 효력을 부정하였다.[63]

1970년 *Plastic Contact Lens v. W.R.S.* 판결에서 뉴욕남부연방지방법원은 실시권자는 실시계약 중의 부쟁조항을 위반하였지만, 그 부쟁조항은 실시권자가 특허무효를 주장하는 것을 금지하지 않는다고 판단하면서 그 판단의 논거를 제시하지 않았다.[64] 여기서 법원은 행위능력이 있는 양 당사자가 기만행위가 존재하지

57) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 669 (1969).

58) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 670-71 (1969).

59) Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co., 444 F.2d 425, 428 (9th Cir. 1971).

60) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 421 F.2d 809, 821 (7th Cir. 1970).

61) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 471 F.2d 149, 153 (7th Cir. 1972).

62) Bendix Corp., 471 F.2d at 154.

63) Bendix Corp., 421 F.2d at 821.

64) Plastic Contact Lens Co. v. W. R. S. Contact Lens Lab'ys, Inc., 330 F. Supp. 441, 443 (S.D.N.Y. 1970).

않는 상황에서 체결한 부쟁조항이고, 실시권자가 특허무효를 주장하지 않는 것에 동의하였다는 사실을[65] 완전히 무시하였다는 비판이 가능할 것이다.[66] 항소심에서 제7구역항소법원은 지방법원과 같이 부쟁조항의 효력을 인정하지 않았지만, 원고가 그 조항을 활용하여 경쟁을 제한하지는 않았으므로 그 조항을 요구한 행위가 권리남용에는 해당하지 않는다고 판단하였다.[67]

1971년의 *Massillon-Cleveland-Akron (MCA) v. Golden State* 사건에서 제9구역항소법원은 소송 전에 체결한 화해합의(settlement agreement) 중의 부쟁조항의 효력을 부정하였다. MCA와 Golden State 등 사이에 특허권 침해 분쟁이 발생하자, 그 분쟁을 해결하기 위한 화해계약이 체결되었다.[68] 그 계약에서 Golden State 등은 해당 특허의 유효를 인정하고 자신의 행위가 특허권을 침해하였다고 인정함과 동시에 직접 또는 간접적으로 그 특허의 무효에 대해 다투지 않겠다고 합의하였다.[69] 법원은 부쟁조항이 포함되는 계약은 계약에 의한 금반언 원칙과 비교했을 때 더욱 강한 통제력이 있지 않고,[70] 실시권자에게 특허의 유효를 다투는 과정에도 실시료의 지불을 요구하게 되면 "공공영역의 사상을 충분히 그리고 자유롭게 사용"하는 연방정책에 위반되는 것과 같이, 부쟁조항도 그러한 정책에 위반되므로 무효이고 집행할 수 없다고 판단하였다.[71] 또한 법원은 부쟁조항이 화해계약에 포함되든 실시계약에 포함되든 그의 유효에 대한 판단에 있어서 다르지 않다고 보았고, 부쟁조항의 유효성을 부정하는 판단은 분쟁해결에 유익하여야 한다는 목표에 어긋날 수 있지만 특허로서 보호할 가치가 없는 사상의 자유경쟁에 관한 정책을 그것보다 더 중요하게 보아야 한다는 점을 제시하였다.[72]

---

65) Plastic Contact, 330 F. Supp. at 442.

66) Christian Chadd Taylor, *No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law*, 69 Ind. L.J. 215, 236 (1993).

67) Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225, 231 (7th Cir. 1972).

68) Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co., 444 F.2d 425, 425 (9th Cir. 1971).

69) *Id.*

70) *Id.*, at 427.

71) *Id.*

72) *Id.*

(다) CAFC의 *Flex-Foot* 판결(2001) 및 *Baseload* 판결(2010)

CAFC가 설립되기 전의 반특허(anti-patent) 정서는 CAFC가 설립됨으로 인해 상당 부분 바뀌게 된다.[73] CAFC가 심리한 *Flex-Foot v. CRP* 사건은 소송이 제기되어 증거개시(discovery)가 이루어진 후에 체결된 부쟁조항에 관한 것이다. 양 당사자는 특허의 유효성과 실시가능성에 대하여 다투는 권리를 포기한다는 내용의 부쟁조항이 포함되는 화해합의를 공판(trial) 전에 체결하였다.[74] 그 사건에서 법원은 침해혐의자가 특허무효를 주장한 적이 있었고 증거개시가 이루어진 상황에서 화해합의 중에 포함된 명확하고 오해의 여지가 없는(clear and unambiguous) 부쟁조항에 따라 자발적으로 소송을 취하한 것이라면 그러한 부쟁조항은 유효하다고 판단하였다.[75]

위 *Flex-Foot* 판결은 증거개시 후의 부쟁조항은 원칙적으로 유효라는 법리를 제시한 것이다. 그러나 *Baseload v. Roberts* 사건에서 법원은 증거개시 여부가 부쟁조항의 유효 여부를 결정하는 유일한 변수는 아니라고 판단하였다. 그 사건에서 CAFC는 *Lear* 판결이 제시한 (나쁜 특허를 무효시키는 것이 유리하다는) 공공이익과 화해를 통한 분쟁해결을 선호하는 공공이익의 양 이익의 균형이 유지되어야 하고, 향후의 특허무효에 대한 다툼을 금지하는 것은 자발적인 화해를 격려하는 공공정책에 유리하며, 그 결과는 부쟁조항을 통해 특허무효의 주장을 포기할 수 있는데 그러한 부쟁조항을 포함하는 계약과 동의명령(consent decree)은 반드시 명백하고 오해의 여지가 없어야 한다.[76] 따라서 특허의 유효 여부에 대하여 소송에서 쟁점이 되지 않았거나 실제로 다툰 적이 없더라도 당사자 간의 계약에 포함되는 부쟁조항은 동의명령과 같이 표현이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우, 미래의 침해소송에서 특허의 유효성을 다투는 행위를 금지할 수 있다고 판단하였다.[77]

---

73) Shashank Upadhye, *Understanding Patent Infringement Under 35 U.S.C. S 271(e): The Collisions Between Patent, Medical Device, and Drug Laws*, 17 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 1, 66 (2000).

74) Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362, 1364 (Fed. Cir. 2001).

75) *Id*, at 1370.

76) Baseload Energy, Inc. v. Roberts, 619 F.3d 1357, 1361-62 (Fed. Cir. 2010).

77) *Id*, at 1363.

(라) CAFC의 *Baseload* 판결(2010) 후 제2항소법원의 *Rates* 판결 및 지방법원 판결들

1) 2012년 제2구역항소법원의 *Rates Technology v. Speakeasy* 판결

Rates 판결은 소송 전의 부쟁조항에 관한 것이다. 법원은 그 조항의 효력을 부정하였지만, 나아가 효력이 인정될 수 있는 부쟁조항의 기준을 제시하였다. Rates는 Speakeasy가 자신의 특허권을 침해하였다는 사실을 발견한 후 "Speakeasy는 어디서든 특허의 유효성에 대해 다툴 수 없다. 그렇지 않으면 위약금 1,200달러를 지불한다"라는 내용의 부쟁조항이 포함되어 있는 화해합의를 체결하였다.[78] 이 사건에서의 부쟁조항도 소송 전 화해합의에 포함된 것이고 법원은 부쟁조항의 효력을 인정하지 않았다. 그러나, 법원은 소송이 개시된 후에 체결된 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하는 것이 소송(분쟁) 해결이 원활하여야 한다는 중요한 공공정책에 부합하고, 소송 전의 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하는 것은 나쁜 특허(bad patent)를 무효시키는 공공이익을 심각하게 약화시킨다고 설시하였다.[79] 그런 견지에서 법원은 증거개시(discovery) 여부가 부쟁조항의 유효성을 판단하는 중요한 기준이 된다고 제시하였다.[80] 즉, 부쟁조항이 증거개시 후 체결된 화해합의에 포함된다면 유효하고, 반면 증거개시 전의 화해합의에 포함된다면 무효하다.[81] 그 이유는 ① 증거개시 후의 부쟁조항은 침해혐의자가 특허의 유효성을 평가할 충분한 기회를 가졌었고 알권리가 충분히 보장된 상황에서 특허의 유효성에 대한 도전을 포기한 것이고, ② 특허의 유효성에 대하여 확실하고 실질적인 분쟁이 존재했다는 것이며 특허권자가 자신의 독자적인 지위를 확보하기 위하여 실시계약을 화해합의의 형식으로 만든 것이 아니기 때문이다.[82]

2) 2013년 *TMI v. Rosen* 판결

대상 사건에서 원고와 피고는 2005년에 실시계약을 체결한 후 2009년 분쟁이

78) Rates Tech. Inc. v. Speakeasy, Inc., 685 F.3d 163, 165 (2d Cir. 2012).
79) *Id.* at 172.
80) *Id.*
81) *Id.*
82) *Id.*

일어나자, 원고는 피고를 상대로 침해소송을 제기하였고, 피고는 원고 특허의 유효성에 대하여 다투지 않겠다는 부쟁조항이 포함되는 실시계약을 다시 체결하였으며, 그 후 원고는 소송을 취하하였다.[83] 이 사건에서 지방법원은 먼저 대상 사건이 CAFC의 *Flex-Foot* 판결과 *Baseload* 판결(방론임에도 불구하고)에 구속됨을 확인하였고,[84] 무효특허를 발굴하는 이익과 분쟁해결을 촉진하는 이익 및 계약자유의 원칙을 존중해야 하는 필요성의 균형을 맞추기 위하여 *Lear* 판결, *Flex-Foot* 판결, *Baseload* 판결을 종합하여 ① 당사자 사이에 종전 소송의 존재 및 그 범위(특허의 유효성에 대하여 종전 소송에서 다투었는지 여부 포함), ② 증거개시의 기회가 있었는지 여부, ③ 특허무효의 주장을 포기한 계약이 소송을 해결하였는지 여부, ④ 명백하고 오해의 여지가 없는 문언으로 특허무효를 청구할 수 있는 권리를 포기한 것인지 여부를 기준으로 판단하는 방법을 제시하였다.[85] 법원은 대상 사안에서 피고가 명확하게 특허무효를 주장하는 것을 포기하였으므로 *Lear* 사건과 달리 계약법 상의 자발적으로 체결된 사적계약의 집행에 관한 정책과 관련되어 있고, *Lear* 사건은 실시권자의 금반언 원칙에 관한 것이며 특허의 유효성에 대한 부쟁의 승낙에 관한 것이 아니므로 계약법의 공공정책이 더욱 납득된다고 판단하였다.[86] *Baseload* 판결에 따르면 ③·④가 동시에 존재하면 부쟁조항은 인정되고,[87] 대상 사건의 사실관계를 위에서 제시한 기준에 따라 분석한 결과 ①·②는 해당하지 않고 ③·④는 해당하여 경쟁이익이 무효특허를 발굴하는 이익보다 더 강하다고 판단하여 부쟁조항을 인정하였다.[88]

3) 2015·2017년 *Ocean Tomo v. PatentRatings; Jonathan Barney* 판결

Barney가 PatentRatings 시스템을 개발한 후 PatentRatings 회사를 설립하였고, Barney는 PatentRatings 및 Ocean Tomo와 일련의 계약을 체결하였고 그 중에 PatentRatings 시스템에 대한 2004년의 실시계약이 포함되어 있다. 그 실시

83) TMI Prod., Inc. v. Rosen Elecs., L.P., No. EDCV1202263RGKSPX, 2013 WL 12114078, at *1-2 (C.D. Cal. Nov. 27, 2013).

84) TMI Prod., , 2013 WL 12114078, at *2.

85) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at *5.

86) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at *7.

87) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at *5.

88) TMI Prod., 2013 WL 12114078, at *7.

계약 중에 부쟁조항이 포함되어 있었으며, 2007년 실시계약을 수정하면서 그 부쟁조항은 그대로 유지되었다.[89] 그들 사이에 분쟁이 발생하자 Ocean Tomo는 Barney와 PatentRatings를 상대로 2개의 소송을 제기하였다.

2015년 판결에서 지방법원은 CAFC가 이미 "화해계약이 일방이 후속 소송에서 특허의 유효성에 대하여 다투는 것을 막을 수 있는지 여부에 관한 문제는 특허권의 집행과 밀접한 관련이 있으므로" CAFC의 선례에 따라야 한다고 판시하였으므로 본안의 부쟁조항에 있어서도 CAFC의 법리에 따라 판단한다고 설시하였다.[90] 법원은 *Lear* 판결의 예외가 되는 화해에 해당하는지를 판단할 때 특허의 유효성에 관한 분쟁 또는 소송이 있었는지 여부가 중요하고 위협 또는 소송이 제기되기 전에 달성한 계약이더라도 예외에 해당할 수 있으며,[91] *Lear* 판결은 실시허가에서 실시권자가 특허의 유효성을 다툴 수 없다고 하였을 뿐 "당사자가 상대적으로 평등한 지위에서 변호사의 도움으로 가치가 있는 대가의 교환을 통하여 특허의 유효성에 대한 이의를 제기할 권리를 충분히 이해하고, 현명히, 명확히 그리고 자발적으로 포기하는 경우"에 대하여 검토한 적은 없다고 판단하였다.[92] 대상 사건에서의 부쟁조항은 명백하고 오해의 여지가 없으며,[93] 2007년에 실시계약을 수정하여 다시 체결한 것은 그때의 분쟁을 해결하기 위한 것이므로 소송 전 화해합의에 해당한다고 판단되어 *Lear* 판결에 따라 해당 부쟁조항이 유효하다고 판단하였다.[94]

이와 반대로 2017년 판결에서 지방법원은 ① 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항이면 집행될 수 있다는 *Baseload* 사건에서의 견해는 방론(dicta)에 해당할 뿐, CAFC는 실질적으로 소송 전 화해계약 중의 부쟁조항에 대하여 판결한 적이 없고,[95] ② CAFC가 말하는 "부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우"의 의미가 명확하지 않고 "화해계약이 있는 배경 하에서 그 전에 특허무효가 쟁

89) Ocean Tomo, LLC v. PatentRatings, LLC, 262 F. Supp. 3d 553, 555 (N.D. Ill. 2017).
90) Ocean Tomo, LLC v. Barney, 133 F. Supp. 3d 1107, 1119-20 (N.D. Ill. 2015).
91) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1122.
92) *Id.*
93) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1122-23.
94) Ocean Tomo, 133 F. Supp. 3d at 1123.
95) Ocean Tomo, 262 F. Supp. at 564.

점이 되었거나 실질적인 소송이 제기된 것"이 요구되지 않는다고 하였으므로 양 당사자 간에 특허의 유효성으로 인해 분쟁이 일어난 것을 요구하는 의미인데 CAFC의 그러한 표현이 미결소송을 종결시키지 못한 화해계약도 부쟁조항을 부정한 *Lear* 판결의 예외에 해당한다는 의미인지는 불명확하고, 어느 법원도 그렇게 인정한 바가 없으며,[96] ③ *Lear* 판결의 예외로 부쟁조항을 인정하는 것은 사법경제를 도모할 수 있는 화해합의에 유리한 공공정책과 동의명령의 기판력에 의한 것이고, CAFC가 *Flex-Foot* 판결에서 강조하듯이 화해합의 중의 부쟁조항이 예외로 될 수 있는 근거는 사법경제 때문인데, 소송 전 화해의 경우 미결소송을 종결시킬 수 있는 소송상화해와 달리 무조건 사법자원을 절약할 수 있는 것이 아니므로 *Baseload* 판결을 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항이 *Lear* 판결의 예외로 된다고 이해하면 안 되며,[97] ④ 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하게 되면 실시계약을 소송 전 화해합의로 이해하는 것을 격려하는 결과를 초래하므로 *Lear* 판결이 보호하는 실시권자의 특허에 대하여 무효를 주장하는 권리를 약화시킬 것이라고[98] 보아 본안 실시계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정하였다.

4) 2017년 *Nat. Alternatives v. Allmax Nutrition* 판결

이 사건에서 양 당사자는 2014년 및 2016년에 실시계약을 체결하였고 두 계약에 동일하게 부쟁조항이 포함되었다.[99] 이에 대하여 지방법원은 *Baseload* 판결이 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항이 집행될 수 있다고 판시하지 않았고, 그 사건에서 양 당사자가 종전의 소송 후에 부쟁조항이 포함되는 화해합의를 체결한 것이고 해당 특허의 유효성은 종전의 소송에서 쟁점이 되지 못한 상황이었으며, CAFC는 "특허무효가 쟁점이 되지 않았거나 실제로 법정에서 다툰 적이 없더라도 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항이면 미래의 침해소송에서의 무효 주장을 막을 수 있다"라고 하였을 뿐, 다시 말하면 *Baseload* 사건은 어떠한 소송도 없는 상황에서 체결한 부쟁조항에 대하여 언급하지 않았다고 보아 *Rates* 판결에서의 법리가 더욱

96) *Id.*

97) Ocean Tomo, 262 F. Supp. 3d at 564-65.

98) Ocean Tomo, 262 F. Supp. 3d at 565.

99) Nat. Alternatives Int'l, Inc. v. Allmax Nutrition, Inc., 258 F. Supp. 3d 1170, 1176-77 (S.D. Cal. 2017).

바람직하다고 판단한 후 해당 부쟁조항의 효력을 부정하였다.[100]

5) 2020년 *Transocean v. Noble* 판결

Transocean은 Noble를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였고 Noble이 실시계약 중의 부쟁조항을 위반하였다고 주장하였으며, 그 실시계약은 전의 침해소송을 해결하기 위하여 체결된 것이다.[101] 먼저 판례법의 적용에 있어서 *Rates* 사건은 계약위반에 대한 배상 청구와 관련되어 있고, *Flex-Foot* 사건과 *Baseload* 사건은 특허권 침해에 대한 배상 청구에 관한 것이며, 본 사건의 경우 계약위반에 대한 배상 청구와 특허권 침해에 대한 배상 청구가 동시에 존재하므로 연방법을 적용할 것인지 주법을 적용할 것이지는 명확하지 않다고 하여,[102] 연방법과 주법을 조화하기 위하여 실시계약 중의 부쟁조항에 대한 해석을 ① 부쟁조항은 공공정책에 부합하여 집행성이 있는지 여부와 ② 집행될 수 있다면 추가적인 사실조사나 배심원단의 평결 없이 법조문에 따라 해당 부쟁조항을 해석할 수 있는지 두 개의 절차로 나누어서 ①은 연방법에 의해 판단하고, ②는 주법에 따라 판단하여야 한다고 설시하였다.[103] 지방법원은 양 당사자는 실시계약의 체결을 통해 전에 제기된 특허권 침해소송을 해결하였고, Noble은 "당사자로서 또는 전 세계적으로 제3자를 재정적으로 지원하여 해당 특허의 어떤 청구항의 범위에 대하여 도전하는 법원 또는 행정 절차에 참여하지 않을 것"을 동의함으로써 연방법에 따르면 이 부쟁조항은 명백하고 오해의 여지가 없으므로 해당 부쟁조항은 유효라고 판단하였다.[104]

6) 2022년 *Gyro-Trac v. King Kong* 판결

원고는 2017년에 피고가 자신의 특허의 권리를 침해하였다는 사실을 알리는 문서를 피고에게 발송하였고 이 문제를 해결하기 위하여 양 당사자는 2019. 1. 30.에 화해합의를 체결하였다.[105] 그 화해합의에서 피고는 더 이상 특허권을 침해하

100) Nat. Alternatives, 258 F. Supp. 3d at 1178.

101) Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. Noble Corp. Plc, 451 F. Supp. 3d 690, 693 (S.D. Tex. 2020).

102) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 696-97.

103) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 697.

104) Transocean Offshore, 451 F. Supp. 3d at 700.

105) Gyro-Trac Corp. v. King Kong Tools, LLC, No. CV 2:21-2137-RMG, 2022 WL 669609, at *1 (D.S.C. Mar. 4, 2022).

지 않고, 원고 특허의 유효성을 인정하였으며, 해당 특허의 소유권, 유효성 등에 이의를 제기하지 않겠다고 동의하였다.[106] 그 후 2021. 11. 8. 원고는 화해합의가 체결된 후에도 피고가 여전히 특허권을 침해한다는 이유로 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다.[107] 법원은 대상 사안에서 화해합의가 체결되기 전에 양 당사자 사이에 특허권 침해에 관한 소송이 제기되지 않았고 그 화해계약이 어떤 소송을 종결시키지도 않았다는 사실을 적시한 후,[108] *Baseload* 판결은 이러한 사안의 부쟁조항에 대하여 검토하지 않았다는 이유로 *Baseload* 판결의 법리를 따르지 않았다. 법원은 *Rates* 판결의 법리에 따라 부쟁조항의 효력을 부정하였다.[109]

(마) 동의명령(consent decree) 중의 부쟁조항

법원에 의한 동의명령은 일반적으로 기판력이 인정되고,[110] 특허권 침해와 특허의 유효성에 관한 내용의 동의명령에 기판력을 인정하는 것이 소송당사자와 공중의 이익에 부합한다.[111] 그러한 법리가 무효로 되어야 하는 특허가 존재하게 할 수 있지만 동의명령은 소송 중의 화해절차에서 형성된 것이고 침해와 유효성은 확정되었으므로 완전히 사적인 실시계약에 의거한 금반언과 대조된다.[112] 그러한 동의명령에 대한 개별적인 조사를 배제하는 것이 "아이디어에 대한 경쟁적 접근의 촉진"이라는 *Lear* 사건의 정책에 부합하고 가장 효과적인 방법이라고 한다.[113]

한편, 실시계약에 특허권 존속기간 만료 후에 지불하는 실시료를 허락한다면 시장은 존속기간이 만료된 후에도 특허권 독점의 영향을 받으므로 그러한 조항은 허용할 수 없다.[114] 다만, 특허권의 존속기간이 만료되었더라도 실시료의 지급이 영업비밀 또는 마케팅 등과 관련된 것이라면 허용될 수 있다.[115] 그러나, 최근 특허

106) *Id.*
107) *Id.*
108) Gyro-Trac, 2022 WL 669609, at *5.
109) *Id.*
110) Wallace Clark & Co. v. Acheson Indus., Inc., 532 F.2d 846, 848 (2d Cir. 1976).
111) Wallace Clark, 532 F.2d at 849.
112) *Id.*
113) Am. Equip. Corp. v. Wikomi Mfg. Co., 630 F.2d 544, 548 (7th Cir. 1980).
114) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, 32-33, 85 S. Ct. 176, 179, 13 L. Ed. 2d 99 (1964).
115) Kimble v. Marvel Ent., LLC, 576 U.S. 446, 454, 135 S. Ct. 2401, 2408, 192 L. Ed. 2d 463 (2015).

권의 존속기간이 만료된 후 실시료의 지급에 관한 *Zimmer v. Insall* 사건에서, 법원은 중재판정에서의 조항은 특허권에 의한 것이 아니므로 허용된다고 설시하였고,[116] 법원은 오직 판정이 "정의가 명확하고 지배적인 공공정책을 위반하는 경우"에 그 판정을 취소할 수 있다고 설명하면서[117] 이 사건 중 중재판정의 해석은 *Brulotte* 판결에서 말하는 정책에 반하지 않는다는 이유로 중재판정을 유지하였다.[118]

(바) 벌칙조항

벌칙조항은 명시적으로 무효심판을 제기하는 것을 금지하진 않지만, 제기한다면 벌칙이 동반되게 하는 조항이다. 다양한 유형의 벌칙조항이 존재하지만, 그들의 공통점은 실시권자가 무효심판을 청구할 동기를 감소시킴으로써 특허권자가 특허심판에 대응해야 하는 위험을 낮추는 것이다.[119]

Lear 사건에서 무효심판이 계속 중인 시기에 실시료를 계속 지급하게 하는 벌칙조항이 쟁점이 되었는데, 연방대법원은 그 조항의 집행성을 부정하였다.[120] *Lear* 판결 중의 조항은 벌칙조항 중에서 상대적으로 정도가 약한 것이라고 볼 수 있고, 그런데도 집행성이 부정되면 기타 정도가 비교적 강한 벌칙조항의 집행성은 더욱 부정되어야 한다는 견해가 있을 수 있다. Server & Singleton은 논문에서 사실상 *Lear* 판결 후에 대부분의 지방법원은 기본 공공정책과 충돌되는 계약조항을 금지하였다고 한다.[121]

Crane v. Aeroquip 사건에서 제7구역항소법원은 *Lear* 판결이 제시한 법리를 더욱 확대하였다. 관련 전용실시계약 중에 실시권자가 실시료를 지불하지 않는 경우 특허권자는 계약을 해지할 수 있는 조항이 포함되어 있었다.[122] 법원은 그러한

116) Zimmer Biomet Holdings, Inc. v. Insall, No. 22 CV 2575, 2023 WL 2895749, at *4 (N.D. Ill. Apr. 11, 2023), aff'd, No. 23-1888, 2024 WL 3381286 (7th Cir. July 12, 2024).

117) Zimmer Biomet, 2023 WL 2895749, at *3.

118) Zimmer Biomet, 2023 WL 2895749, at *6.

119) Alan D. Miller & Michal S. Gal, supra, at 131 (2015).

120) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 674 (1969).

121) Alfred C. Server & Peter Singleton, *Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing*, 3 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243, 337-54 (2011).

122) Michal S. Gal & Alan D. Miller, *Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense?*, 102 Iowa L. Rev. 1477, 1487 (2017).

조항도 금반언이 특허에 대한 정당한 도전에 미치는 영향과 같은 효과를 나타낼 것이라는 이유로 계약이 해지되지 않는다고 판단하였다.[123]

그러나 그러한 상황은 CAFC의 설립에 따라 달라졌다. CAFC는 나쁜 특허를 소멸시키는 것이 공중이익에 부합하지만, 실시권자가 특허를 무효시키는 경향이 부작용을 가져올 수 있다고 보았다.[124][125] *Lear* 판결의 적용범위를 축소할 때 법원은 특허보호를 통한 창작의 촉진, 분쟁 해결, 안정 및 계약자유 등 다양한 목표를 강조하였다.[126] 대법원이 벌칙조항을 명백히 금지하기 전에는 합법이라는 견해도 있었다.[127] CAFC의 판사가 *Lear* 판결의 법리는 이미 시대에 뒤떨어졌고 창작을 촉진하자는 국가이익에 부합하지 않는다고 지적하기도 했다.[128]

(3) 검토

Lear 사건에서는 부쟁조항이 존재하지도 않았었고, 해당 판결은 오직 실시권자 금반언 원칙을 폐기하였고, 계약자유의 원칙에 대하여 언급하지도 않았다.[129] 실시계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정한 법원은 *Lear* 사건에 계약자유의 이익이 언급되지 않았음에도 불구하고 부쟁조항을 금반언과 동일시하여 금지한 것이고, 계약자유의 이익과 장점을 완전히 고려하지 않은 것이다.[130] *Plastic* 사건에서 법원은 부쟁조항의 존재 자체가 반드시 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없고, 경쟁을 제한하는 경우에만 집행성이 부정되어야 한다고 보았다.[131] 법원은 창조를 격려하는 정책과 발명을 공중에게 공개하는 정책을 무시하였고 그것들은 자유경쟁의 정책과 동일하게 중요하다.[132] 또한 자유협상의 산물인 실시계약이 지지되지 않고 부쟁조항의 효력이 부정되면 앞으로는 많은 발명자들이 특허출원을 하기보다 해당

123) Crane Co. v. Aeroquip Corp., 504 F.2d 1086, 1092 (7th Cir. 1974).
124) Michal S. Gal & Alan D. Miller, supra, at 1487 (2017).
125) Server & Singleton, supra, at 354 & n.378 (providing a list of Federal Circuit cases relating to this issue).
126) Michal S. Gal & Alan D. Miller, supra, at 1487 (2017).
127) Cordis Corp. v. Medtronic, Inc., 780 F.2d 991, 993 (Fed. Cir. 1985).
128) Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1228 (Fed. Cir. 1988).
129) Christian Chadd Taylor, supra, at 225.
130) *Id.* at 238-39.
131) *Id.* at 239.
132) *Id.* at 227-28.

기술을 영업비밀로 보호하게 될 것이다. 그러한 결과로 발명자는 자신의 기술을 보호할 수 있는 동시에 기술을 공개하지 않아도 되고 영업비밀의 실시를 통해 이익을 얻을 수 있으며 특허와 달리 존속기간의 제한도 없다.[133] 하지만 기술을 영업비밀로 보호하는 경향이 강해지면 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허제도의 목적을 달성할 수 없게 되므로, 이러한 견지에서도 부쟁조항을 일정한 범위 내에서는 인정하는 것이 공중의 이익에 더욱 부합한다고 생각된다.[134]

분쟁이 임박한 때 또는 발생한 후 실시계약을 체결하는 경우도 있으므로, 그 실시계약을 소송 전 화해합의와 구별하기 어렵다는 현실적 어려움도 존재한다.[135] 화해합의에 포함된 부쟁조항에 대하여 나쁜 특허의 발굴과 자유로운 사상의 이용을 우선 고려하는 다른 항소법원들과 달리 CAFC는 기판력과 화해합의와 집행을 강조한다.[136] 위에서 본 바와 같이 2001년 *Flex-Foot* 사건에서 증거개시 후에 체결된 부쟁조항은 유효하다고 보았고, 2010년 *Baseload* 사건에서는 부쟁조항이 명백하다면 분쟁이 없었더라도 유효할 수 있다고 설시하였다. 그러한 판결에 대하여 ① CAFC는 경쟁이 점점 치열해지고 있는 환경 하에서 미국이 기술을 진보시키기 위하여 부쟁조항은 집행되어야 하고, 특허권자가 제3자에게 실시허락을 통해 연구개발비를 회수할 수 있어야 하는 점을 인식하였고,[137] ② 계약자유가 단기적으로는 공중이 자유로운 아이디어에 접근하는 것을 제한할 수 있지만 부쟁조항의 추가로 인해 감소된 실시료가 전체적으로 창조를 촉진할 것이며 이로써 소비자는 더욱 저렴한 가격으로 더욱 많은 기술의 진보를 취득할 수 있으므로[138] CAFC의 판시가 현실에 부합하고 더욱 바람직하다는 견해가 있다.[139] 필자도 이러한 견해에 공감한다.

---

133) Richard Weil Goldstucker, *Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders' Rights in Patent Licensing Agreements*, 16 J. Intell. Prop. L. 137, 157 (2008).

134) *Id.*

135) Rates Tech. Inc. v. Speakeasy, Inc., 685 F.3d 163, 173 (2d Cir. 2012).

136) Melissa Brenner, *Slowing the Rates of Innovation: How the Second Circuit's Ban on Nochallenge Clauses in Pre-Litigation Settlement Agreements Hinders Business Growth*, 54 B.C.L. Rev. E-Supplement 57, 64 (2013).

137) *Id.* at 66.

138) *Id.* at 67.

139) *Id.* at 69.

다 유럽의 관련 법리

미국과 달리, 유럽은 경쟁법을 적용하여 부쟁조항의 유효 여부를 판단한다.[140] 유럽연합기능조약(Treaty establishing the European Economic Community, TEFU) 제101조 제1항이[141] 사업자 간의 모든 합의, 사업자단체에 의한 결정, 시장의 경쟁을 막거나 제한, 왜곡하는 것을 목적으로 하는 동조적 행위 등은 금지되어야 한다고 규정한다. 그러한 결정, 합의 등은 제2조에[142] 따르면 자동으로 무효가 된다. 다만, 그러한 결정, 합의 등은 상품의 제조 또는 분배를 조장하거나 기술 또는 경제의 진보를 촉진하여 이로부터 소비자가 합리적으로 이익을 취득할 수 있는 동시에 관련 업체에 불필요한 제한을 부가하지 않고 관련 시장에서의 어떤 중요한 부분의 경쟁을 배제하지 않았더라면 제101조 제1항이 규정하는 금지행위에 해당하지 않는다.[143] 특허실시계약에서의 부쟁조항이 이러한 조건을 충족하기는 어려워 보인다.

Windsurfing International v. Commission 특허사건에서 유럽사법재판소(European Court of Justice)는[144] 경제효과에 대하여 심사하지 않았고, 해당 부쟁조항에 대하여는 특허권의 고유한 대상에 속하지 않고 공공이익을 고려했을 때 특허권을 잘못 부여해서 사업자 사이의 경쟁을 부당하게 제한하게 되어 TEFU 제101조 제1항(구 제85조 제1항)에 부합하지 않는다고 보았다.[145]

그 후 유럽사법재판소는 *Bayer v. Süllhöfer* 사건에서 부쟁조항이 원칙적으로 TEFU 제101조 제1항이 규정하는 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다는 보는 것은 바람직하지 않고, 부쟁조항의 적법성을 판단할 때 법적 및 경제적 배경을 고려하여야 한다고 설명하였다.[146] 구체적으로 ① 부쟁조항이 포함되는 특허실시계약에서

140) Thomas K. Cheng, supra, at 460.
141) TEFU Article 101(1).
142) TEFU Article 101(2).
143) TEFU Article 101(3).
144) 현재는 the Court of Justice of the European Union으로 변경되었다.
145) Case C-193/83 Windsurfing Int'l, Inc. v. Commission, 1986 E.C.R. 633-664.
146) Case 65/86, Bayer AG v. Süllhöfer, 1988 E.C.R. 5285-5286.

실시료가 무료인 경우 실시권자는 실시료의 지급으로 인해 경쟁에서 불리한 지위에 있는 것이 아니므로 경쟁을 제한하지 않고, ② 대상 특허발명이 낙후된 기술인 경우 실시료의 지급이 요구된다고 하더라도 그러한 실시계약 중의 부쟁조항은 경쟁을 제한하지 않는다.[147] 또한 부쟁조항이 소송을 종결시키기 위하여 체결된 계약에 포함된 것이라도 일반 실시계약과 다를 바가 없다고 판단하였다.[148] 이러한 판단은 분쟁을 화해에 의해 해결하는 것이 공공정책에 부합하는 측면을 외면한 것이라고 생각된다.

TTBER(Technology Transfer Block Exemption Regulation) 제5조 제1항 b호도 부쟁조항을 규율한다. TTBER이 적용되는 실시계약의 대상에는 특허, 실용신안 등이 포함된다.[149] 그 조항에 의하면 특허무효를 주장하면 계약위반의 책임을 부담하는 조항과 특허무효를 주장하면 실시계약이 종결되는 조항은 면제되지 않고, 전용실시(exclusive licence)계약 중의 부쟁조항인 경우 TEFU 제101조 제1항에서 면제된다.[150] 전용실시권자가 특허무효를 주장하는 상황은 타당하지 않다고 본 것이다.

기술이전협약에 대한 유럽연합기능조약 제101조의 적용 가이드라인에서 부쟁조항을 면제범위에서 배제하는 이유는 실시권자가 특허의 유효성을 판단하는 제일 적합한 자이고, 무효로 되어야 할 특허는 혁신을 촉진시키지 않고 이를 저해할 것이기 때문이라고 밝혔다.[151] 기술이 가치가 있으므로 사용하지 못하거나 실시료를 지급하여야 기술을 사용할 수 있는 업체가 경쟁열위를 부담할 수 있는 경우에 TEFU 제101조 제1항이 적용될 수 있다.[152]

Bayer 판결이 기술이 낙후된 경우 또는 실시가 무료인 경우에 경쟁을 제한하지 않는다는 설시하였는데, 그 점은 가이드라인에서도 다시 확인할 수 있다.[153] 따라

147) Case 65/86, Bayer AG v. Süllhöfer, 1988 E.C.R. 5286.

148) *Id.*

149) TTBER Article 1.

150) TTBER Article 5.

151) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (2014/C 89/03) 134.

152) *Id.*

153) *Id.*

서 TTBER과 가이드라인의 규정을 결합하면 특허권의 실시에 관하여 실시가 전용실시인 경우, 실시가 무료인 경우, 특허발명이 낙후된 것인 경우에 경쟁을 제한하지 않으므로 TEFU 제101조 제3항이 적용된다. 더불어, 시장에 특허발명에 대한 대체기술이 많은 경우에도 적용될 것이다.

한편, 최근 *Huawei v. ZTE* 사건에서 부쟁조항과 관련된 내용은 언급되지 않았지만, 실시권자가 대상 특허의 유효성을 다투는 권리의 중요성을 다시 확인하였다. 이 사건에서 법무고문(Advocate General) Wathelet씨가 공중이익의 측면에서 침해혐의자가 실시계약을 체결한 후 표준필수특허의 유효성을 다툴 기회가 있는 것은 매우 중요하고, 잘못 등록된 특허는 합법적인 경제활동에 장애가 될 수 있으며, 표준 관련 제품과 서비스를 제공하는 업체가 표준필수특허의 유효성을 다툴 수 없다면 기타 업체가 그러한 소송을 제기할 확률은 매우 낮으므로 해당 특허의 무효 여부를 검증하는 것은 불가능하게 된다고 보았다.[154] 유럽사법재판소는 그러한 관점에 동의하였고 헌장(Charter) 제47조가 규정한 유효한 사법 보호권에 따르면 침해혐의자가 실시계약의 체결 과정에서 해당 특허의 유효성을 질의하거나 미래에 질의하는 권리를 보유하는 것에 대해 비판해서는 안 된다고 설시하였다.[155] 즉, 표준필수특허에 관한 부쟁조항은 원칙적으로 무효이다. 표준필수특허의 강력한 힘 및 반경쟁적 효과를 감안하면, 그러한 판단이 타당하다고 생각된다.

라 독일의 관련 법리

종전의 독일 연방대법원은 당사자 간의 관계에 따라 특허의 유효성을 도전하는 것이 신의칙에 반하는 행위로 평가될 수 있다면 그 무효소송은 권리의 부당한 행사로 간주된다고 보았다.[156] 이러한 경우에 합법적이고 유효한 계약의 이행의 확보, 법원자원의 남용 방지, 제3자의 침해행위로 인한 공중의 손해 등 방면의 정책이

154) Case C-170/13, Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., 2014 Curia ECLI:EU:C:2014:2391 *95 (Nov. 20, 2014).

155) Case C-170/13, Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp., 2015 Curia ECLI: EU:C:2015:477 *69 (July 16, 2015).

156) GRUR 1990, 667, beck-online.

나쁜 특허를 제거하는 정책보다 우선이어야 한다고 보았다.[157] 즉, 특허무효소송에서 신의칙에 의한 부쟁의무가 요구될 수 있었다. 다만, 지식재산권에 관한 분쟁에서 (전체적으로 유럽 배경하에서) 달성한 합의 중의 부쟁조항에 대해서는 계약법상 문제가 없다면 구 TEFU 제85조 제1항의 규정에 따라 평가하게 된다.[158][159]

독일 구 경쟁제한금지법 제17조 제2항 제3호는 부쟁조항에 대해 규정하였다.[160] 즉, 특허권자와 특허의 양수인 또는 실시권자 사이의 부쟁조항은 양수인 또는 실시권자가 불합리한 제한을 받지 않았고 그 제한의 정도가 시장경쟁을 엄중하게 저해하지 않았다면 적법하다는 것이었다.[161] 다만, 그 규정은 2005년 개정에 따라 폐지되었고,[162] 현재는 유럽 TEFU 제101조와 상응하는 취지로 특허권자와 특허의 양수인 또는 실시권자 사이의 부쟁조항은 특허권의 권리범위를 초과하는 상업적 제한을 부가하므로 원칙적으로 불법이고 무효라고 보고 있다(당연무효는 아니다).[163]

그러나, 무효소송이[164] 제기된 때 특허권자에게 계약을 해지할 수 있는 권리를 부여하는 계약해지조항은 허락되고, 신의칙에 근거한 부쟁의무도 허용된다.[165] 즉, 원고가 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 반한다고 인정되면 법원은 실질적인 심리를 하지 않는 상태에서 사건을 각하할 수 있다.[166] 예를 들어, 오랜 시간이 지난 후 제기된 소송은 신뢰보호의 원칙에 따라 모든 상황을 종합적으로 고려한 후 소권의 남용으로 인정될 수 있고, 양 당사자 간에 계약의 제약이 존재하는 경우에 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 위반되는 행위로 소권의 남용으로 인정될

157) *Id.*
158) GRUR Int 1997, 631, beck-online.
159) *Id.*
160) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.
161) 구 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen § 17 Abs. 2 Nr. 3.
162) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.
163) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.
164) 독일에서는 특허무효심판이 존재하지 않고 특허법원이 특허무효소송 1심을 담당하고, 그 후 최고법원에서 2심(최종심)을 담당한다.
165) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.
166) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 43, beck-online.

수 있다. 그 전제로는 당사자 간의 계약이 합법이어야 하고 유럽 TEFU 제101조를 위반해서는 안 된다.[167] 이러한 경우에 연방대법원은 보호할 가치가 없는 특허를 정식적으로 취소하는 것보다 공중이익을 고려해서 계약을 유효하게 이행할 수 있도록 하여야 하고, 제3자의 악의적인 공격으로 인해 공중이익이 피해보는 행위를 방지하는 것을 우선시하여야 한다고 보았다.[168]

구체적으로 실시권자가 무효소송을 제기하는 행위는 신의칙에 반할 수 있고(반드시 반하는 것은 아님), 일반적으로 ① 실시권자가 전용실시권자인 경우, ② 실시관계가 일종의 회사관계의 특징을 가지고 있는 경우, ③ 개량특허에 대한 무료실시인 경우 등 상황에서 제기된 무효소송은 신의칙에 반하여 위법이라고 인정될 수 있으므로[169] 원칙적으로 부쟁조항이 없더라도 부쟁의무를 부담한다고 해석할 수 있다. 그러한 경우의 부쟁의무는 통상적으로 실시계약이 종결될 때까지 유지된다고 보지만, 쌍방의 관계가 매우 밀접하고 실시계약이 종결된 후에도 지속적으로 신의성실의무를 발생시키거나 부쟁조항의 기간이 실시계약이 종결된 후까지 연장되는 경우에는 그렇지 않다.[170]

계약 중의 부쟁조항의 효력에 대하여 독점금지법 상의 의문이 있을 때 독일 민사소송법 제148조에 따라 소송은 독점금지 사항을 담당하는 법원이 그 조항의 합법성에 대한 재결을 내릴 때까지 중지되어야 한다.[171]

한편, 화해합의를 통해 분쟁을 해결하는 것은 분쟁의 계속 또는 미래 회복을 포기함으로써 쟁의가 있는 특허권에 대한 진일보의 공격을 포기하는 것이므로 일반적인 실시계약과 비교했을 때, 화해의 목적으로 체결한 실시계약 중의 부쟁조항은 부수적인 의무보다는 그러한 의무가 없으면 계약 체결을 불가능하게 하는 주요 의무라 할 수 있다. 심지어 부쟁조항을 화해합의 중 고유한 의무라 할 수 있고, 명문의 부쟁조항이 규정되어 있지 않더라도 그러한 의무는 존재한다. 다만, 해당 특허

167) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22, beck-online.
168) BGH - Einbettungsmasse, GRUR 1990, 667, beck-online.
169) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 44, beck-online.
170) *Id.*
171) Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81, beck-online.

가 명백하게 무효라면 부쟁조항이 포함되는 화해합의가 기록될 수 없다고 한다.[172][173]

독일의 기준을 요약하면, 먼저 부쟁조항이 특허권의 범위를 초과하는 상업적 제한을 부가하였다면 무효이고, 부쟁조항이 유럽 TEFU 제101조를 위반하지 않고 남용, 철회, 종결, 취소 등 기타 원인으로 효력을 상실하지 않았다면 유효하다고 볼 수 있고[174] 제기된 무효소송은 신의칙에 반하여 소권의 남용으로 인정될 수 있다. 부쟁조항이 없더라도 특정한 경우에는 부쟁의무를 부담하게 되므로 실시권자가 무효소송을 제기하는 것이 신의칙에 반한다고 인정될 수 있다.

마 중국의 관련 법리

중국 민법전 제850조는 "불법적으로 기술을 독점하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다"라고 규정하고,[175] 최고인민법원은 이에 대하여 기술사용을 허락받는 자가 계약의 대상이 되는 지식재산권의 유효 여부에 대해 이의를 제기하는 것을 금지하거나 그러한 이의를 제기하는 데 조건을 붙이는 행위는 민법전 제850조가 규정하는 불법적으로 기술을 독점하는 행위에 해당한다고 해석한 바 있다.[176]

2015. 2. 10. 중국발전개혁위원회는 Qualcomm에게 행정처벌을 내린 바가 있다.[177] Qualcomm이 실시권자가 베이스밴드 칩을 취득하는 조건으로 실시계약의 체결과 부쟁조항을 요구하였다.[178] 예컨대, 불합리한 조항이 포함되는 특허실시계약을 체결하지 않은 잠재적인 실시권자인 경우 Qualcomm은 베이스밴드 칩 매매계약의 체결을 거절하고 베이스밴드 칩의 제공을 거부하고, 이미 실시계약을 체결

172) *Id.*
173) GRUR Int 1997, 631, beck-online.
174) BPatG Urt. v. 2.3.2016 - 2 Ni 15/14 (EP), BeckRS 2016, 11049, beck-online.
175) 《中华人民共和国民法典》第八百五十条.
176) 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条.
177) 国家发展和改革委员会行政处罚决定书[2015]1号.
178) 上揭决定书.

한 실시권자인 경우 실시계약에 관하여 분쟁이 발생하여 소송을 제기하게 되면 Qualcomm은 그 실시권자에게 더 이상 베이스밴드 칩을 제공하지 않았다.[179] 그러한 행위에 대하여 중국발전개혁위원회는 "실시계약에 관하여 분쟁이 발생하여 소송을 제기하는 것은 실시권자의 권리이고, Qualcomm은 자신의 베이스밴드 칩 분야에서의 지배적인 지위에 기하여 베이스밴드 칩 매매계약 중에 실시계약에 대한 불합리한 부쟁조항을 부가하는 행위는 실질적으로 실시권자의 권리를 제한하거나 박탈하는 것이므로 그러한 행위는 정당한 이유가 없다. 또한 Qualcomm은 지배적 지위를 갖고 있으므로 베이스밴드 칩의 제공을 거부하면 불합리한 조항이 포함되는 실시계약을 체결하지 않는 실시권자를 시장에서 배척하여 시장경쟁을 배제·제한하게 된다"고 판단하였다.[180]

한편, 2015. 8. 1. 시행된 "경쟁을 배제·제한하는 지식재산권 남용 행위의 금지에 관한 규정"(이하 '남용금지규정') 제10조에 따르면 시장지배적 지위를 가진 회사는 지식재산권을 행사하는 과정에서 정당한 이유 없이 거래상대방이 자신의 지식재산권의 유효성에 대하여 이의를 제기하는 것을 금지하는 불합리한 조건을 부가하는 행위를 해서는 안 된다.[181] 그 후 2019년 "지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침"(이하 '2019 반독점 지침') 제10조에서 부쟁조항이 시장경쟁에 대한 배제, 제한적인 영향을 분석하는 몇 가지 요소를 제시하였다. 그 요소로서 ① 실시허락자가 모든 실시권자에게 지식재산권의 유효성을 다투지 못하도록 요구하는지 여부, ② 부쟁조항의 대상인 지식재산권의 실시가 유료인지 여부, ③ 부쟁조항의 대상인 지식재산권이 하위시장의 진입장벽을 구성할 가능성이 있는지 여부, ④ 부쟁조항의 대상인 지식재산권이 기타 경쟁적 지식재산권의 실시를 저해하는지 여부, ⑤ 부쟁조항의 대상인 지식재산권의 실시가 배타적인지 여부, ⑥ 실시권자가 지식재산권의 유효성에 이의를 제기할 때 중대한 손실을 볼 가능성이 있는지 여부가 있다.[182]

위의 규정들 외에 중국 대외무역법 제30조가 "지식재산권에 대한 권리를 가지는

179) 上揭决定书.
180) 上揭决定书.
181) 《关于禁止滥用知识产权排除限制竞争行为的规定》第十条.
182) 《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》第十条.

자가 실시허락계약에서 그 지식재산의 실시허락을 받는 자가 지식재산권의 유효성에 대하여 이의를 제기하지 못하게 하거나, 강제적인 일괄허가를 진행하거나, 계약에서 배타적·독점적 그랜트 백(grant-back) 조건을 정하는 등의 행위 중 하나를 하여 대외무역의 공정한 경쟁질서에 위해를 가하게 되는 경우 국무원 대외무역 주관부서는 그 위해를 제거하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있다"라고 규정한다.[183]

그러한 규정에 대하여 다음과 같은 비판이 존재한다.

첫째, 대외무역법에 따르면 계약 중의 부쟁조항으로 인해 대외무역의 경쟁에 위해를 초래하여야만 그 조항에 대하여 조치를 취할 수 있으므로 부쟁조항 자체는 금지되지 않는 것이고 그 조항이 무조건 경쟁에 반한다고 단정할 수도 없으며 그의 영향은 구체적인 상황에 따라 개별적으로 분석하여야 할 것이다.[184] 2019 반독점 지침 제10조에 따르면 부쟁조항이라 하더라도 경쟁을 배제·제한하지 않을 수도 있으므로 허용되는 부쟁조항도 있을 것으로 생각된다. 그러나, 민법전과 최고인민법원의 해석에 따르면 부쟁조항의 존재 자체가 불법적으로 기술을 독점하는 행위이고 기술의 발전에 저해하기 때문에 조항의 영향을 판단할 필요도 없이 조항 자체가 불법이고 무효이며 법률에 의하여 금지되는 조항이다.[185] 그러한 규정들은 서로 충돌하는 내용이 포함되어 있고, 실제 적용에 있어서 대외무역법은 외국에 관련된 실시계약 또는 국제적인 실시계약 중의 부쟁조항에 대하여 합리적 분석의 원칙이 적용되고 국내의 실시계약 중의 부쟁조항에 대하여 금지규정이 적용되어 전면적으로 그 효력 또는 유효성을 부인하게 되므로 적용에 차별이 존재하고 적절하지 않다.[186]

둘째, 민법전과 최고인민법원의 해석이 특허법의 관련 규정과 충돌한다. 중국 특허법 제47조에 따르면 특허무효선고의 결정은 이미 이행한 특허실시계약과 특허권 양도계약에 대하여 소급효를 갖지 않으므로 특허실시계약의 대상 특허가 무효선고되어도 실시권자가 그전에 지급한 실시료는 일반적으로 반환하지 않아도 된다. 그

183) 《中华人民共和国对外贸易法》第30条.
184) 吴广海, "专利技术许可中不质疑条款的法律规制", 科技进步与对策2011年第9期, 2011, 107页.
185) 吴广海, 上揭论文, 107页.
186) 吴广海, 上揭论文, 107页.

러한 규정은 실시계약 또는 관련 조항이 유효한 전제에서 적용되는 것이고, 만약 실시계약이 부쟁조항으로 인해 무효되면 그 실시계약으로 취득한 재산은 반환하여야 하므로 실시권자는 그러한 틈새를 악용하여 특허의 무료 실시를 도모할 수 있고 이는 특허권자에게 불공평한 결과를 초래한다.[187] 그러나, 부쟁조항이 존재하더라도 해당 조항만 무효인 것이고 실시계약 전체가 무효인 것은 아니므로, 이 비판에는 동의하기 어렵다.

셋째, 특허권자의 입장에서는 부쟁조항은 자신의 특허권을 안정시키고 관련된 이익을 보장하는 일종의 수단이며, 부쟁조항의 존재 자체도 실시허락의 촉진과 실시료의 감소에 유익하게 작용하는 장점이 있으므로 민법전의 부쟁조항에 대한 금지규정은 부쟁조항이 가지는 긍정적인 측면을 외면한 결과이다.[188] 이러한 견지에서 (앞에서 상세히 살펴본 바와 같이) 미국 법원이 제법 많은 사건에서 부쟁조항이 유효하다고 판단한 것이다.

그러한 현실에 대하여 ① 규정과 해석은 지식재산의 유형을 구분하여 다르게 취급하지 아니한 잘못이 있고, 그러한 부쟁조항은 특허발명에 대하여는 무효이지만, 노하우에 대하여는 유효로 보아야 하고 화해합의 중의 부쟁조항의 경우는 특허에 대한 것이든 노하우에 대한 것이든 모두 유효로 보아야 한다는 견해,[189] ② 부쟁조항에 대하여 부정적인 입장을 취하지 않고 특허실시계약에서의 존재를 인정하여야 하며, 이를 철회할 수 있는 조항으로 취급하여야 한다는 견해[190] 등이 있다.

한편, 민법전 및 최고인민법원의 해석에 따르면 부쟁조항은 원칙적으로 무효이고 금지될 뿐만 아니라 경쟁을 배제, 제한하는 행위로 간주된다. 남용금지규정과 2019 반독점 지침에 따르면 시장지배적 지위를 가진 회사가 부쟁조항을 부가하는 행위는 허용되지 않고, 규정되어 있는 요소에 따라 경쟁에 대한 영향을 분석함으로써 경쟁을 제한하지 않는 부쟁조항도 존재한다는 점을 알 수 있다. 즉, 민법과 경쟁법 분야에서의 법률의 규정들이 서로 일치하지 않고 적용에 있어서 혼란이 존재하는 상황이다.

187) 吴广海, 上揭论文, 107页.
188) 吴广海, 上揭论文, 107页.
189) 张海涛, “美欧‘不质疑条款’效力比较及其借鉴”, 知识产权2011年第8期, 2011, 88页.
190) 吴广海, 前揭论文, 107页.

중국의 법리를 종합적으로 정리하면, 중국에서는 부쟁조항을 일반적으로 무효로 보는 분위기가 강하며, 일부 학자들이 미국의 법리와 유사한 법리를 주장하고 있다. 아직은 중국에서 특허권을 우호적으로 보지 않는 분위기가 우호적으로 보는 분위기보다 더 강한 것으로 관측된다.

바 일본의 관련 법리

실시권자가 누리고 있는 이익은 특허의 유효를 전제로 하므로 실시권자가 자신이 실시하는 특허(발명)에 대하여 무효심판을 청구하는 것이 신의칙에 반하는지 여부가 문제인데 통설과 판례는 반하지 아니한다는 입장을 취하고 있다.[191][192] 이에 대하여 실시권자가 실시계약을 체결할 때 해당 특허가 유효하다고 믿고 체결을 결정한 것이고 만약 계약 체결 후 실시권자가 무효사유를 발견하였는데도 그 특허를 근거로 하여 실시료의 지급을 계속 요구받는 것은 가혹하며, 또한 실시계약을 체결할 때 해당 특허의 유효성에 대하여 의문이 있더라도 실시계약을 체결하지 않은 상황에서 무효심판을 청구하는 것은 시간과 금전적으로 어려운 점이 있고 결과도 확정하지 못하므로 처음부터 무효심판을 청구하는 것은 불합리하고 실시계약을 체결하였다는 이유만으로 실시권자가 특허권의 유효성에 대하여 쟁의하지 아니하겠다는 의도를 표명했다고 할 수 없다는 등을 이유로 들고 있다.[193]

그러나, 실시계약 중에 부쟁조항이 포함되어 있는 경우에 부쟁조항을 허용할 것인지 여부에 관하여 학설은 ① 공익적으로 무효사유가 존재하는 특허에 대한 부쟁의무를 허용한다면 일반 자유를 제한하는 결과를 초래하므로 독점금지법상 문제가 될 수 있지만, 모인(冒認)이 무효사유일 때에는 그렇지 않다는 견해, ② 신의칙에 따라 허용하여야 한다는 견해, ③ 허용하지 않아야 한다는 견해로 나누어진다.[194] 그 중 원칙적으로 부쟁조항을 유효라고 보는 견해가 다수설이다.[195]

191) 中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2019, 539頁.

192) 岡田洋一, "権利不争義務に関する訴訟法的考察", 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書, 2021, 9頁 각주 22 참조.

193) 中山信弘, 前揭書, 539頁.

194) 中山信弘·小泉直樹, 新·註解特許法下卷第2版, 青林書院, 2017, 2522~2523頁.

195) 최지호, 앞의 논문, 10면.

"지식재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침" 제4조의 4(7)에서 "실시권자가 특허기술에 대해서, 특허기술과 관련되는 권리의 유효성에 대해 다투지 않는 의무를 부과하는 행위는 원활한 기술거래를 통하여 경쟁의 촉진에 이바지하는 면이 인정되고, 직접적으로 경쟁을 감소할 우려는 작지만, 무효로 되어야 할 특허권이 존속하면 해당 권리와 관련되는 기술의 이용이 제한되는 것으로부터 공정한 경쟁에 방해되는 것으로써 불공정한 거래방법에 해당하는 경우도 있다. 그 밖에 실시권자가 특허의 유효성에 이의를 제기하는 경우 해당 특허에 관한 실시계약을 종결시키는 행위도 원칙적으로 불공정거래행위에 해당하지 않는다."라고[196] 하여 부쟁조항의 적법성을 인정하였고 무효로 되어야 할 권리는 불공정거래방법에 해당할 수 있다는 취지이다. 그러한 부쟁조항을 설치한다고 하더라도 실시권자만 제약하고 제3자는 자유롭게 무효심판을 청구할 수 있으므로 즉시 공중의 이익을 해하지는 않는다.[197] 또한 계약자유의 원칙에 따르면 강행법규에 위반되어야만 유효성을 부정할 수 있고, 계약에서 부쟁조항을 약정하여 실시권자에게 무효심판청구 금지의무를 부여하는 것은 공서양속에 위반한다고 할 수 없음에 따라 무효가 아니고 오히려 실시계약 체결과 특허발명의 실시를 촉진할 수 있다고 본다.[198][199]

사 대만지구의 관련 법리

대만 공정거래위원회는 특허권자가 실시권자에게 해당 특허의 유효성을 다투는 것을 제한하는 행위가 특정 시장에 경쟁을 제한하거나 공평한 경쟁에 방해하는 우려가 있다면 그러한 행위를 하면 안 된다고 규정한 바 있고,[200] 그 규정에 위반되는 행위는 공정거래법 제45조가 규정하는 특허권의 정당한 권리행사 행위에 해당하지 않는다.[201] 이를 부쟁조항이 실시계약 중에 포함되는 것을 금지하는 것은 아

196) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第4, 〈https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html〉 2024.4.22. 최종방문.

197) 岡田洋一, 前揭報告書, iii頁.

198) 中山信弘, 前揭書, 539頁.

199) 岡田洋一, 前揭報告書, iii頁.

200) 公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則 第六.

201) 邱馨萱, "技術授權協議中關於智慧財產有效性之「不挑戰」條款之有效性及競爭法之規範分析——以專利權之「不挑戰」條款為例", 專利師第三十六期, 中華民國專利師公會, 2019, 130頁.

니고 그 조항이 관련 시장의 경쟁을 제한할 수 있는 때만 부당하다고 본다고 해석할 수 있다.[202] 여기서 경쟁을 제한하는지를 판단하는 요소는 아직 제시되어 있지 않다.[203]

또한 실시권자가 그러한 부쟁조항을 위반할 때 특허권자에게 실시계약을 종결하는 권리를 부여하는 것이 규정에 실시권자의 특허 유효성 다툼의 권리를 제한하는 행위에 해당하는지, 그로 인하여 경쟁을 제한하거나 공평한 경쟁에 방해하는 우려가 있는지에 관하여 아직 법원의 설명이 필요한 상황이다.[204]

4 특허무효 관련 부쟁조항과 관련된 필자의 제안

가 주요국 법리의 정리

주요국들 모두 부쟁조항이 당연히 무효라고 보지는 않는다. 부쟁조항의 허용 여부에 대하여 유럽과 중국, 대만지구는 경쟁법의 측면에서 규율하고, 미국은 특허제도와 계약법의 측면에서 부쟁조항의 집행성을 판단한다.

미국의 경우 1969년 *Lear v. Adkins* 연방대법원 판결이 실시권자 금반언(licensee estoppel) 원칙을 폐기하였고, 그 판결 이후 미국의 많은 법원들이 부쟁조항은 일반적으로 집행불능(unenforceable)인 것으로 판단하였다.[205][206] 더 나아가서 부쟁조항을 요구한 특허권자의 행위가 특허권의 남용에 해당할 수 있다고 판단한 사례도 존재한다.[207] 다른 한편, 그러한 행위가 특허권의 남용에 해당

202) 邱馨萱, 上揭論文, 130頁.

203) 邱馨萱, 上揭論文, 130頁.

204) 陳伯翰, "專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還——智慧財產法院101年度民專上字第58號判決的影響評估", 智慧財產權月刊第194期, 經濟部智慧財產局, 2015, 82頁.

205) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970); Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advert. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971); Plastic Contact Lens Co. v. W. R. S. Contact Lens Lab'ys, Inc., 330 F. Supp. 441 (S.D.N.Y. 1970).

206) Raymond T. Nimmer and Jeff C. Dodd, Modern Licensing Law § 9:43, Thomson West (2024).

207) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 471 F.2d 149, 158 (7th Cir. 1972) (noting that "no contest"

하지는 않는다고 판단한 사례도 존재한다.[208] 한편, 일반적인 실시계약이 아닌 화해합의에서의 부쟁조항은 유효로 판단될 가능성이 더 높지만,[209] 무효로 본 사례도 존재한다.[210]

하지만, 위의 다양한 판례들은 CAFC가 설립되기(1982) 전인 1970년대의 것들이어서 이제는 선례로서의 가치가 낮은 것이 사실이다. CAFC의 해당 쟁점에 대한 입장이 중요한데, CAFC는 부쟁조항에 대해 1970년대 법원들보다 더 우호적인 입장을 보여왔다. 2001년의 *Flex-Foot v. CRP* 사건에서 양 당사자는 소송 제기 후 특허 유효 여부에 대하여 증거개시가 이루어진 후 화해계약을 체결하였고 그 계약이 부쟁조항을 포함하였는데, CAFC는 화해합의가 자발적으로 체결된 계약인 경우 그 계약에서의 부쟁조항은 유효인 것으로 판단될 수 있다고 설시하였다.[211] 더 나아가, 2010년의 *Baseload Energy v. Roberts* 사건에서 CAFC는 화해합의에서의 부쟁조항이 유효한지 여부에 대하여는 사안별로(case-by-case) 판단해야 한다는 점과 부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는(clear and unambiguous) 경우에 유효할 수 있다고 설시하였다.[212]

Flex-Foot 판결과 *Baseload* 판결에 따라 CAFC의 입장이 상대적으로 확정되었음에도 불구하고 *Rates v. Speakeasy* 사건에서 제2구역항소법원은 여전히 소송 전에 체결된 부쟁조항의 효력을 부정하였다.[213] 지방법원의 판례인 경우 CAFC의 법리를 적용하여 분쟁 또는 소송을 해결하기 위하여 체결한 부쟁조항의 효력을 긍정하는 판례가 있고,[214] 실시계약 중의 부쟁조항 또는 분쟁을 해결하기 위한 화

provision could potentially constitute patent misuse).

208) Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225, 230-31, 16 Fed. R. Serv. 2d 1208 (7th Cir. 1972); Congoleum Industries, Inc. v. Armstrong Cork Co., 366 F. Supp. 220, 233 (E.D. Pa. 1973), judgment aff'd, 510 F.2d 334 (3d Cir. 1975).

209) Wallace Clark & Co., Inc. v. Acheson Industries, Inc., 532 F.2d 846, 849 (2d Cir. 1976); Houston Atlas, Inc. v. Del Mar Scientific, Inc., 217 U.S.P.Q. 1032, 1982 WL 51051 (N.D. Tex. 1982), aff'd, 703 F.2d 555 (5th Cir. 1983).

210) Kaspar Wire Works, Inc. v. Leco Engineering & Mach., Inc., 575 F.2d 530 (5th Cir. 1978).

211) Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362, 1368-70 (Fed. Cir. 2001).

212) Baseload Energy, Inc. v. Roberts, 619 F.3d 1357, 1362 (Fed. Cir. 2010).

213) Rates Technology Inc. v. Speakeasy, Inc., 685 F.3d 163 (2d Cir. 2012).

214) Nat. Alternatives Int'l, Inc. v. Allmax Nutrition, Inc., 258 F. Supp. 3d 1170 (S.D. Cal.

해계약 중의 부쟁조항의 효력을 부정하는 판례도 존재한다.[215] 심지어 같은 사실관계 하에서 제기된 2건의 소송에서 실시계약 중의 부쟁조항의 효력에 대하여 정반대의 입장을 보이기도 하였다.[216]

〈표 1〉 미국의 법리 정리

미국	*Lear* 판결 전의 시기	
	실시권자 금반언 원칙 폐기	Lear v. Adkins (1969)
	Lear 판결(1969)부터 CAFC 설립(1982) 전의 시기: **부쟁조항 불허용**	
	(실시계약 중의) 부쟁조항은 특허권자의 독점적 권리에 해당하지 않으므로 부쟁조항은 무효	Bendix v. Balax (1970)
	(분쟁을 해결하기 위하여 소송 전에 체결한 화해합의 중의) 부쟁조항은 '공공영역의 사상을 충분히 그리고 자유롭게 사용'할 수 있어야 한다는 연방정책에 어긋나고 그 정책은 분쟁해결의 정책보다 더욱 우선시해야 하므로 무효	MCA v. Golden State (1971)
	(실시계약 중의) 부쟁조항이 경쟁을 제한하지 않았으므로 권리남용에 해당하지 않았음에도 불구하고 부쟁조항은 무효	Plastic Contact v. W.R.S. (1972)
	CAFC의 *Flex-Foot* 판결 및 *Baseload* 판결: **경우에 따라 허용**	
	(소송 중 증거개시 후 체결된 화해합의 중의) 부쟁조항의 경우 무효를 주장했었고 당사자는 증거개시를 할 기회가 있었으며 명확하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항에 따라 자발적으로 소송을 취하하였다면 허용	Flex-Foot v. CRP (2001)
	부쟁조항을 인정하는 것은 무효특허를 발굴하는 정책과 화해를 조정하는 정책의 균형을 맞추어야 함; 소송 쟁점이 되지 않았거나 특허의 유효성에 관하여 법정에서 실제로 다툰 적이 없더라도 명확하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항은 허용	Baseload Energy v. Roberts (2010)

2017); Gyro-Trac Corp. v. King Kong Tools, LLC, No. CV 2:21-2137-RMG, 2022 WL 669609 (D.S.C. Mar. 4, 2022).

215) TMI Prod., Inc. v. Rosen Elecs., L.P., No. EDCV1202263RGKSPX, 2013 WL 12114078 (C.D. Cal. Nov. 27, 2013); Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. Noble Corp. Plc, 451 F. Supp. 3d 690 (S.D. Tex. 2020).

216) Ocean Tomo, LLC v. Barney, 133 F. Supp. 3d 1107 (N.D. Ill. 2015); Ocean Tomo, LLC v. PatentRatings, LLC, 262 F. Supp. 3d 553 (N.D. Ill. 2017).

	CAFC의 *Baseload* 판결(2010) 후 제2항소법원의 *Rates* 판결 및 지방법원 판결들	
	(소송 전에 체결된) 부쟁조항의 효력을 부정하였고, (증거개시 후에 체결된) 부쟁조항의 경우 당사자가 특허의 유효성을 충분히 평가할 수 있고 알권리가 보장되는 상황에서 부쟁을 동의한 것이고 실질적인 분쟁이 존재하는 것이며 실시계약을 화해계약의 형식으로 만드는 경우를 배제할 수 있으므로 **유효**	Rates v. Speakeasy (2012)
	(분쟁을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항에 있어서 실시권자의 금반언 원칙에 관한 *Lear* 판결보다는 계약법의 공공정책이 더욱 납득되고, *Baseload* 판결의 법리를 적용하여 부쟁조항이 포함되는 계약이 소송을 해결하였고 그 조항이 명백하고 오해의 여지가 없으므로 **유효**	TMI v. Rosen (2013)
	(분쟁을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항에 대하여 2015년 판결: CAFC의 판결에 따라 분쟁을 해결하기 위하여 체결된 명백하고 오해의 여지가 없는 부쟁조항은 **유효** 2017년 판결: CAFC가 말하는 "부쟁조항의 문언이 명확하고 오해의 여지가 없는 경우"의 의미가 명확하지 않고, 실질적으로 소송 전 화해합의에 대하여 판결한 것이 아니며, 소송 전 화해합의가 반드시 사법자원을 절약하는 것이 아니며, 소송 전 화해합의 중의 부쟁조항을 인정하게 되면 실시계약을 소송 전 화해합의로 위조하는 행위를 격려하는 결과를 초래할 것 등에 비추어 화해계약으로 보는지 여부와 관련 없이 소송 전의 계약에 포함되는 본안 부쟁조항은 **무효**	Ocean Tomo v. PatentRatings; Jonathan Barney (2015) (2017)
	(실시계약 중의) 부쟁조항에 있어서 *Baseload* 판결은 소송이 존재하지 않는 상황에서 체결한 부쟁조항에 대하여 언급하지 않았으므로 *Rates* 판결에서의 법리를 적용하여 **무효**	Nat. Alternatives v. Allmax (2017)
	(소송을 해결하기 위한 실시계약 중의) 부쟁조항의 유효성에 있어서 연방법의 적용을 받아 명백하고 오해의 여지가 없으므로 **유효**	Transocean v. Noble (2020)
	(분쟁을 해결하기 위한 화해계약 중의) 부쟁조항에 대하여 *Baseload* 판결은 유사한 상황에 대하여 다루지 않았으므로 *Rates* 판결의 법리에 따라 **무효**	Gyro-Trac v. King Kong (2022)

부쟁조항에 대한 주요국의 태도 변화를 정리해 보면 다음의 표와 같다.

〈표 2〉 주요국 태도 변화

국가	구 — — — · · · · · · — — → 현				추세
미국	금반언 원칙 채택 →	부쟁조항 불허용 →	증거개시 후의 부쟁조항 허용 →	소송 전 부쟁조항도 허용할 수 있음	엄격→유연
한국	상표분야의 이해관계의 사전포기약정은 무효[217] →	부쟁의무 부과는 불공정거래행위에 해당[218] →	시장지배력을 보유한 사업자가 도입한 부쟁조항은 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단될 수 있음[219] →	부쟁조항은 유효할 가능성이 있음[220][221]	엄격→유연
독일	신의칙에 의한 부쟁의무가 요구될 수 있음[222] 유럽특허가 포함된다면 구 TEFU 제85조 제1항에 따라 평가[223] 시장경쟁을 엄중하게 손해하지 않으면 유효[224] →	TEFU 제101조와 상응하는 취지로 원칙적으로 무효로 봄[225] 계약해지조항은 유효; 신의칙에 반한다고 인정되면 유효[226]			유연→엄격
유럽	표준필수특허에 대한 실시계약에서의 부쟁조항은 무효[227] 일반적으로 무효; 실시가 무료인 경우의 부쟁조항은 허용; 실시 특허가 낙후된 기술인 경우의 부쟁조항은 허용[228] 전용실시인 경우의 부쟁조항은 허용[229]				엄격
중국	민법과 경쟁법의 적용에 있어서 혼란이 존재함 경쟁법의 측면에서 판단할 때 경쟁에 대하여 배제·제한적인 영향을 미치지 않는 부쟁조항의 경우 유효로 볼 수 있음[230]				엄격
일본	부쟁조항은 원칙적으로 허용하지만, 무효로 되어야 하는 특허권의 존재는 불공정거래방법에 해당할 수 있음[231]				유연
대만 지구	부쟁조항이 경쟁을 제한하는 때만 허용하지 않음[232]				유연

217) 대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78, 79, 80 판결.

218) 1997년「국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준」제3조.

219) 2010년「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」.

220) 특허법원 2009. 11. 6. 선고 2009허1996 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허1989 판결, 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결 등.

221) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

222) GRUR 1990, 667, beck-online.

223) GRUR Int 1997, 631, beck-online; GRUR Int 1997, 631, beck-online.

224) 구 독일 경쟁제한금지법 제17조 제2항 제3호.

미국은 금반언 원칙을 채택하면서 차차로 부쟁조항을 허용하는 추세를 보여주었다. 한국도 엄격하게 부쟁조항을 무효로 취급하다가 차츰 부쟁조항에 대한 제한을 풀어주었다. 일본 및 대만지구는 경쟁에 미치는 영향에 대한 판단기준을 자세히 제시하지 않았고 원칙적으로는 유효로 보아 유연한 태도를 보였다. 반면 중국은 지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침 제10조에서 규정한 요소에 따라 판단하여 경쟁에 대하여 배제·제한적인 영향을 미치지 않는 부쟁조항의 경우 유효로 볼 수 있다는 입장인데 민법전과 경쟁법의 적용에 있어서 혼란이 존재하는 상황이고, 일반적으로는 부쟁조항이 무효로 판단된 가능성이 높은 법리가 운영되고 있다. 유럽도 마찬가지로 표준필수특허에 대한 부쟁조항은 무효이고, 실시가 무료인 경우, 실시 특허가 낙후된 기술인 경우 및 실시가 전용실시인 경우를 제외하는 기타 경우의 부쟁조항은 일반적으로 무효로 보아 부쟁조항을 엄격하게 제한하고 있다. 독일은 예전에는 부쟁조항을 유효로 보기도 하였으나, 최근에는 유럽과 유사한 기준을 적용하여 부쟁조항이 유효하려면 유럽 TEFU 제101조에 위반되지 않아야 한다.

나 부쟁조항 유효 여부를 판단하는 법리의 제안

부쟁조항의 효력의 판단에 있어서 일률적으로 효력을 긍정하거나 부정하기보다 그 부쟁조항의 경쟁을 제한 또는 촉진하는 정도, 무효특허를 발굴하는 공중의 이익, 계약자유의 원칙 및 분쟁해결의 목적 등 여러 이익의 균형을 고려해서 판단하여야 한다.[233] 다양한 부쟁조항의 성질, 유형 및 체결경위 등 요소를 고려하면 단

225) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.
226) Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 43, beck-online.
227) Huawei v. ZTE 사건.
228) Bayer v. Sullhofer 사건; 유럽연합기능조약 제101조의 적용 가이드라인 134.
229) TTBER 제5조 제1항 b호.
230) 2019년 지식재산 분야에 관한 국무원반독점위원회 반독점 지침 제10조.
231) 지식재산의 이용에 관한 독점금지법상 지침 제4의 4(7).
232) 공정거래위원회 기술실시계약에 대한 처리원칙 제6조.
233) 송영환, “지적재산권 라이센스 거절에 대한 공정거래법의 적용 - EU 신규칙 및 일본의 신지침을 중

순히 독점금지법 측면 또는 단순히 특허법 측면에서 판단하는 것은 적절하지 않고, 독점금지법 및 특허법을 결합하여서 상황에 따라 판단하여야 한다. 이에 다음의 순서로 판단하는 것을 제안한다.

먼저, 해당 특허기술의 시장지배력 및 독점권이 미치는 범위를 판단한다. 예컨대 상당한 시장지배력을 갖는 표준필수특허 또는 독점권이 미치는 범위가 상당히 넓고 공중의 이익에 미치는 영향이 큰 경우에 해당하는 부쟁조항은 경쟁을 지나치게 배제하므로 원칙적으로 무효라고 보아야 한다.[234][235] 반면 실시가 무료인 경우, 특허기술이 낙후된 경우, 대체기술이 많은 경우 등 거래, 시장에 미치는 영향이 제한적인 경우의 부쟁조항은 유효라고 보아야 할 것이다.[236]

다음으로, 시장지배력 및 독점권이 미치는 범위가 작은 특허에 대한 부쟁조항의 경우, 특허법의 측면에서 그 조항이 체결된 경위에 따라 사안별로 구체적으로 판단한다. 부쟁조항은 한편으로는 실시권자에게 무효심판을 청구하지 못하게 특허권자가 강요한 측면이 있고, 다른 한편으로는 실시권자가 특허의 무효를 다투지 않겠다고 약속한 측면이 있다.[237] 전자를 '수동적 부쟁조항'이라고 칭할 수 있고, 그 부쟁조항은 무효로 판단될 가능성이 더 높아야 할 것이다. 후자를 '능동적 부쟁조항'이라고 칭할 수 있고, 그 부쟁조항은 유효로 판단될 가능성이 더 높아야 할 것이다. 제소전화해 또는 소송상화해에서의 부쟁조항은 대표적인 능동적 부쟁조항에 해당한다. 일반적인 실시계약에서의 부쟁조항은 수동적 부쟁조항일 가능성이 더 높을 것이나, 획일적으로 단정할 것은 아니다. 그런 점에서 실시계약의 이력을 살펴서 해당 부쟁조항이 수동적 부쟁조항인지 아니면 능동적 부쟁조항인지를 판단해야 할 것이다. 구체적으로 다음과 같다.

첫째, 어떤 소송 또는 분쟁이 발생하지 않은 상황에서 체결된 일반적인 실시계약은 수동적 부쟁조항에 해당할 가능성이 높다. 특별한 사정이 없다면 해당 부쟁조항은 무효로 보고, 특허의 실시가 무료인 경우, 특허기술이 낙후된 경우, 전용실시계

심으로 -", 한양법학 제29집, 한양법학회, 2010, 650면.

234) 이혜진, 앞의 논문, 625면.

235) 前揭决定书.

236) 이혜진, 앞의 논문, 625면.

237) 이혜진, 위의 논문, 625면.

약인 경우에는 유효로 본다. 그리고, 실시권자가 실시료의 감소 등을 대가로 부쟁조항을 도입할 것을 자발적으로 요구한 경우의 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효로 보아야 한다. 또한 실시계약의 체결 과정에 변호사가 도움을 주어 해당 특허의 무효에 대하여 전면적으로 검토할 수 있었고 부쟁조항의 문언이 명백한 경우에는 유효로 볼 가능성이 높을 것이다.

둘째, 분쟁 또는 소송을 해결하기 위하여 (증거개시 전에) 체결한 계약에서의 부쟁조항의 효력을 인정한다면, 화해를 통한 분쟁해결을 촉진함으로써 사법자원을 절약할 수 있다. 따라서 분쟁이 존재했었다는 점이 증명되고, 문언이 명백한 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효로 보아야 한다. 다만, 분쟁이 발생하여 이미 소송이 제기된 경우에는 분쟁의 존재를 증명할 필요가 없다. 이러한 경우 체결된 계약이 화해합의가 아니라 실시계약일지라도 분쟁을 해결하였으므로 화해합의와 동일하게 취급하여 그 부쟁조항도 유효로 본다.

셋째, 소송이 상당히 진행되어 특허무효 여부에 대하여도 충분히 검토된 후에 성사된 합의의 경우, 당사자가 해당 특허의 유효성에 대하여 충분히 평가할 기회가 있었고, 특허를 무효시키는 확률에 대하여 충분히 평가한 후 자발적으로 부쟁조항이 포함되는 화해를 선택한 것이므로 그러한 부쟁조항은 능동적 부쟁조항에 해당하여 유효이다.

넷째, 화해에 따라 법원에서의 화해조서가 이루어진 경우 그 화해조서는 확정판결과 같은 효력이 발생하므로, 그 조서 중에 포함하는 부쟁조항은 기판력에 따라 당연히 유효이다.[238)]

위에서 필자가 제안한 법리들은 다음의 표와 같이 정리될 수 있다.

238) 민사소송법 제220조.

〈표 3〉 법리 제안

효력	step 1: 독점금지법 기준	step 2: 특허법 기준	성질
유효 ↑	실시가 무료인 경우/ 특허기술이 낙후된 경우 (Bayer v. Sullhofer; 유럽연합기능조약 제101조의 적용 가이드라인 134) 전용실시인 경우 (TTBER 제5조 제1항 b호)	화해조서에 기록된 부쟁조항 (민사소송법 제220조)	능동적 ↑
		소송 중 화해합의/실시계약 중의 부쟁조항 (미국 Rates 판결/Baseload 판결)	
		소송 전 분쟁 후 화해합의/실시계약 중의 부쟁조항 (미국 Baseload 판결)	
↓ 무효		분쟁 전 실시권자의 자발적인 추가에 따른 실시계약 중의 부쟁조항	↓ 수동적
	표준필수특허에 관한 부쟁조항 (Huawei v. ZTE)	분쟁 전 일반 실시계약 중의 부쟁조항 (미국 Baseload 판결)	

다 특허권자 입장에서의 실시계약 작성 전략

(1) 미국의 법리

미국에서 2001년 *Flex-Foot* 판결 및 2010년 *Baseload* 판결에서 CAFC가 부쟁조항의 유효 여부에 대하여 판단한 후, 지방법원 판결들이 유사한 상황에서 다른 판단을 하고 있음을 확인하였다. 그런 점에서 CAFC가 더 정확한 법리를 제시할 것이 기다려진다. 그럼에도 불구하고 CAFC가 부쟁조항에 대해 판단할 기회를 가지지 못하는 이유는 무엇일까?

필자는 특허권자가 부쟁조항을 요구하면서 관련 벌칙조항도 같이 요구함에 따라 실시권자가 특허무효를 다투는 위험을 감수하지 않고 있고 그래서 관련 판결이 생산되지 않는다고 추측한다. 특허무효를 다투어서 해당 부쟁조항이 무효라는 판단,

나아가 벌칙조항도 무효라는 판단을 얻어낼 것이 확실치 않은 상황에서 실시권자가 특허무효를 다투기를 꺼릴 것이 예상된다. 그러한 결과로 관련 사건이 많지 않고 CAFC가 더 정교한 법리를 제시할 기회를 가지지 못하는 것으로 생각된다.

그렇다면, 실시계약을 체결함에 있어서 특허권자는 부쟁조항 및 관련 벌칙조항을 실시계약에 포함시키도록 노력하여야 할 것이다. 그러한 규정들을 두는 (특허무효를 다투는 것을 방지하는 효과의) 이익이 해당 규정(들)이 무효라고 판단되어 받게 되는 불이익에 비하여 더 큰 것으로 생각된다. 더욱이, 부쟁조항이 무효라고 판단되어도 그 부쟁조항을 요구한 행위가 특허권 남용이라고 판단된 가능성은 매우 낮다고 보아야 한다. 위에서 살펴본 사례에서 특허권 남용을 인정한 사례는 발견되지 않았다.

(2) 실시계약 종료조항

무효심판 청구시 실시계약이 자동으로 종료되게 하는 소위 실시계약 종료조항은 실시권자를 위협하는 효과를 가지므로 실시권자가 특허를 무효시킬 가능성을 높게 보는 경우에만 무효심판을 청구할 것이기 때문에 대부분의 무효심판 청구를 막을 수 있다.[239]

(3) 일시불 실시료 요구

특허권자는 일시불 실시료와 (매출액에 연동되는) 경상실시료(running royalty) 중 일시불 실시료의 비중을 더 높일 필요가 있다. 현행 법리에 따르면, 실시계약을 통해 실시권자가 특허권자에게 이미 지불한 실시료는 돌려받을 수 없다.[240] 즉, 실시권자가 해당 특허를 무효시키더라도 이미 지불한 실시료를 돌려받을 수 없고 그 액수가 상당하면, 실시권자가 특허를 무효시킬 동기가 약화될 것이다.

라 실시권자 입장에서의 실시계약 작성 전략

실시계약을 작성함에 있어서 특허권자가 부쟁조항을 둘 것을 요구하는 경우, 실

239) Thomas K. Cheng, supra, at 442-43.
240) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결.

시권자는 그 요구를 거부하기 어렵다. 실시계약을 체결하는 그 장면에서 장래에 특허무효를 주장하기 위하여 부쟁조항을 거부하는 것은 실시계약을 깨는 행위가 될 수 있다. 실시권자의 입장에서 부쟁조항의 존치를 거부하기 어렵다면 향후 그 부쟁조항이 무효로 판단될 가능성을 높이기 위해 노력해야 한다. 그러한 노력의 일환으로 해당 부쟁조항이 능동적인 것이 아니라 수동적인 것임에 대한 증거를 잘 정리, 보관하여야 한다. 또한 위에서 본 바와 같이 기지불한 실시료는 돌려받을 수 없으므로 실시권자가 실시계약을 체결할 때 일시불 실시료를 되도록 피하는 것이 유익하다.

5 결 론

대법원 2017후2819 전원합의체 판결이 실시권자가 원칙적으로 대상 특허에 대해 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인임을 확인하였다. 그래서 특허권자는 실시계약 체결 후 실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있는 가능성에 대비하여 실시계약, 화해계약 등에 특허무효의 다툼을 금지하는 소위 부쟁조항을 두게 된다. 본 논문은 특허무효심판의 청구를 금지하는 부쟁조항이 유효한지 여부를 판단하는 기준을 찾기 위하여 미국, 유럽, 독일, 중국, 일본 등의 법리를 비교, 분석하였다. 그러한 비교, 분석의 결과로 분 논문은 부쟁조항의 유효 여부의 판단에 대하여 다음과 같은 법리를 적용하는 것을 제안한다.

첫째, 부쟁조항의 효력을 일률적으로 긍정하거나 부정하는 법리는 적절하지 않다. 부쟁조항은 한편으로는 (나쁜 특허가 계속 존재하도록 하여) 경쟁을 제한하는 측면이 있을 수 있지만, 다른 한편으로는 실시계약의 체결을 촉진함으로써 경쟁을 촉진하는 측면도 있고 특허권자의 지위를 강화함으로써 기술개발 또는 기술이전을 촉진하여 산업발전에도 기여할 수 있는 장점을 가지고 있다.

둘째, 독점권, 배타권이 매우 강한 특허에 대한 부쟁조항은 무효일 가능성이 더 높다고 보아야 한다. 즉, 표준필수특허 또는 시장지배력이 크거나 독점권이 미치는 범위가 넓은 특허에 대한 부쟁조항은 원칙적으로 무효이다.

셋째, 원칙적으로 무효인 부쟁조항에 해당하지 않는다면, 계약자유의 원칙 및 분쟁의 대체적(자율적) 해결이라는 목적을 고려하는 측면에서 부쟁조항을 수동적 부쟁조항과 능동적 부쟁조항으로 나눈다. 수동적 부쟁조항의 경우 일반적으로 무효로 보고, 특별하게 실시가 무료인 경우 또는 특허기술이 낙후된 경우 등 거래, 시장에 미치는 영향이 제한적이라면 유효로 본다. 능동적 부쟁조항의 경우, 실시계약에 포함되는지 화해계약에 포함되는지를 불문하고, 분쟁을 해결하기 위하여 체결된 것이고 문언이 명백하다면 유효로 본다.

넷째, 화해조서에 포함된 부쟁조항의 경우 확정판결과 같은 기판력이 발생하여 당연히 유효이다.

부쟁조항이 무효로 판단될 가능성이 작지 않다. 하지만 부쟁조항이 장차 무효로 판단되더라도 특허권자의 입장에서는 실시계약에 포함시키는 것이 유리하다. 실시권자가 부쟁조항을 위반하는 경우 실시계약이 해지되는 벌칙조항을 두게 되면, 실시권자가 섣불리 특허무효심판을 청구할 수 없으므로 부쟁조항의 존재만으로도 실시권자를 위협할 수 있다. 부쟁조항을 두는 것이 특허권자에게 해로울 것이 없다. 반면 실시권자의 입장에서는 특허의 실시권을 얻기 위해서 특허권자의 요구를 거부할 수 없을 가능성이 크다. 따라서 실시권자로서는 부쟁조항을 두는 것을 인정하더라도 해당 조항이 수동적 부쟁조항임을 보여주는 증거를 확보해 두어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 김동준, “실시권자의 특허무효심판청구에 관한 소고”, 충남대학교 법학연구 제18권 제2호, 충남대학교 법학연구소, 2007.
2. 김수철, “실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010.
3. 김현호, “특허심판의 당사자”, 발명특허 제35권 제1호, 한국발명진흥회, 2010.
4. 박영규, “무효심판의 당사자로서 실시권자”, 경영법률 제24권 제3호, 한국경영법률학회, 2014.
5. 박영규, “특허실시계약과 경쟁의 자유 - 유럽의 기술이전 일괄적용면제규칙((EC) No 772/2004)을 중심으로 -”, 경영법률 제20권 제2호, 한국경영법률학회, 2010.
6. 박준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -”, 산업재산권 제54호, 한국지식재산학회, 2017.
7. 송영환, “지적재산권 라이센스 거절에 대한 공정거래법의 적용 - EU 신규칙 및 일본의 신지침을 중심으로 -”, 한양법학 제29집, 한양법학회, 2010.
8. 이서영·정차호, “전용실시권자(exclusive licensee)의 특허무효심판 청구인 적격”, 법학연구 제35권 제3호, 충남대학교 법학연구소, 2024.
9. 이수미·신규환, “특허 실시권자의 무효심판 청구 권리와 부제소 특약의 효력에 관한 연구”, 산업재산권 제64호, 한국지식재산학회, 2020.
10. 이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 – 이해관계인 및 특허풀, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 통권 제49호, 사법발전재단, 2019.
11. 이종우, “전용실시권자와 특허무효심판의 청구인 적격 - 대법원 선고 2019. 2. 21. 2017후2819 전원합의체 판결을 중심으로 - ”, 2019년 TOP 10 특허판례 세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020.

12. 정차호·양성미, “특허무효심판 청구인 적격 - ‘이해관계인’에서 ‘누구든지’로 확대 방안 -”, 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014.

13. 최지호, “특허실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제1호, 한국지식재산연구원, 2008.

14. 이서영, “특허법에서의 실시권자의 당사자 적격에 관한 연구”, 성균관대학교 석사학위논문, 2024.

15. Raymond T. Nimmer and Jeff C. Dodd, Modern Licensing Law § 9:43, Thomson West (2024).

16. Alan D. Miller & Michal S. Gal, *Licensee Patent Challenges*, 32 Yale J. on Reg. 121 (2015).

17. Alfred C. Server & Peter Singleton, *Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing©*, 3 Hastings Sci. & Tech. L.J. 243 (2011).

18. Christian Chadd Taylor, *No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law*, 69 Ind. L.J. 215 (1993).

19. Melissa Brenner, *Slowing the Rates of Innovation: How the Second Circuit's Ban on Nochallenge Clauses in Pre-Litigation Settlement Agreements Hinders Business Growth*, 54 B.C.L. Rev. E-Supplement 57 (2013).

20. Michal S. Gal, Alan D. Miller, *Patent Challenge Clauses: A New Antitrust Offense?*, 102 Iowa L. Rev. 1477 (2017).

21. Richard Weil Goldstucker, *Stop the Bleeding: Medimmune Ends the Unjustified Erosion of Patent Holders' Rights in Patent Licensing Agreements*, 16 J. Intell. Prop. L. 137 (2008).

22. Scott G. Greene, *The Return of the King: Rethinking Lear, MedImmune, and the Effects of Licensee Estoppel in the Context*

of AIA Post-Grant Procedures, 71 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 81 (2015).

23. Shashank Upadhye, *Understanding Patent Infringement Under 35 U.S.C. S 271(e): The Collisions Between Patent, Medical Device, and Drug Laws*, 17 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 1, 66 (2000).
24. Thomas K. Cheng, *Antitrust Treatment of the No Challenge Clause*, 5 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 437 (2016).
25. Benkard PatG/Kober-Dehm, 12. Aufl. 2023, PatG § 22 Rn. 41, beck-online.
26. Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 81 Rn. 95, beck-online.
27. 宁立志, 专利的竞争法规制研究, 中国人民大学出版社, 2021.
28. 陳伯翰, “專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還——智慧財產法院101年度民專上字第58號判決的影響評估”, 智慧財產權月刊第194期, 經濟部智慧財產局, 2015.
29. 邱馨萱, “技術授權協議中關於智慧財產有效性之「不挑戰」條款之有效性及競爭法之規範分析——以專利權之「不挑戰」條款為例”, 專利師第三十六期, 中華民國專利師公會, 2019.
30. 吴广海, “专利技术许可中不质疑条款的法律规制”, 科技进步与对策2011年第9期, 2011.
31. 张海涛, “美欧‘不质疑条款’效力比较及其借鉴”, 知识产权 2011年第8期, 2011.
32. 中山信弘·小泉直樹, 新·註解特許法下卷第2版, 青林書院, 2017.
33. 中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2019.
34. 岡田洋一, “権利不争義務に関する訴訟法的考察”, 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書, 2021.